

neo fué inmediatamente aplicado como ley en vigor. Tanto más que en un pasaje de las *Institutiones* (III, 21) los compiladores justinianos dicen claramente cuál era el concepto que sobre la estipulación se abría camino en la ciencia jurídica de su tiempo. Es verdad —dicen— que los *nomina transscripticia* descritos por GAYO no existen ya en el nuevo derecho, pero una obligación literal existe también ahora si después de la redacción de un documento de estipulación han transcurrido dos años sin que el deudor haya intentado la *querela non numeratae pecuniae*: "sic fit, ut et hodie... *scriptura obligetur, et ex ea nascitur condictio*". Aquí los compiladores se han animado más que en la ya citada constitución, a poner en claro el espíritu del nuevo derecho; y éste se manifiesta decididamente en el sentido de la transformación de la *stipulatio* de contrato verbal en documento escrito, que se convierte en contrato literal cuando ya no es posible hacer valer contra la escritura la falta de causa.

En definitiva, como era natural en el paso de una forma-módulo a una forma-vestidura (cfr. ps. 89 y ss.), la importancia de la causa está destacada en el derecho justiniano. Para el caso principal de la estipulación dirigida a dar forma solemne a un mutuo, se da al deudor, aparte de una *exceptio non numeratae pecuniae* a oponer contra la acción del acreedor (correspondiente a la *exceptio doli* del derecho clásico), también una *querela* del mismo nombre, con la que él puede solicitar a su iniciativa la anulación de la estipulación, remedio ya introducido en la legislación imperial, y ejercible a partir de Diocleciano, dentro de los cinco años, pero reducido por JUSTINIANO al término de un bienio. Así, en materia de querella como de *exceptio*, hay una derogación a los principios que regulan la carga de la prueba, en el sentido de que una vez intentada la querella u opuesta la excepción, corresponde al acreedor probar la existencia de la causa³⁸.

³⁸ La frecuente alusión al *consensus* en las constituciones posteriores y en los textos interpolados, encuentra la mayor parte de las veces su explicación en este mayor relieve de la causa; ello revela, en suma, la desaparición no del formalismo externo sino del interno. Por otra parte, las diversas reducciones llevadas a la forma verbal no deben entenderse a la letra, es decir, en el sentido de la validez de una estipulación oral cuyas partes se hayan expresado con palabras libres, sino como pertenecientes a las declaraciones que las partes hacen ante el notario y a la reproducción escrita por obra del oficial público; en efecto, era natural que una vez trasladada al escrito la formalidad esencial, el contenido de

7. En la concepción romana es también contrato formal el *iudicium*, es decir —en el significado clásico de la expresión— la fórmula que, previa autorización del magistrado, el actor propone al demandado y éste acepta para deferir la controversia al conocimiento de un *iudex privatus* (cfr. ps. 151 y ss.). En particular, toda vez que un *iudicium* tiene por objeto una obligación, ésta se extingue en el momento en que las partes se ponen de acuerdo sobre la fórmula, y en su lugar surge una obligación nueva, cuya causa está precisamente en el *iudicium*, y que GAYO (III, 180) describe como *condemnari oportere*. Descripción ciertamente inexacta porque es absurdo atribuir al demandado “la obligación de ser condenado”; corresponde más bien referirse al originario carácter arbitral del proceso, e interpretar la nueva *obligatio* como compromiso bilateral de aceptar la futura sentencia del juez³⁹.

GAYO limita expresamente tal eficacia obligatoria a las *iudicia legitima*, excluyendo de ella a los *quae imperio continentur* (cfr. p. 156). No parece que la limite ulteriormente a los casos en que se obre *in personam*; y de todos modos resulta de otros textos que los romanos veían un *contractus* también en el acuerdo sobre la fórmula de una *actio in rem*⁴⁰.

Una estructura análoga al *iudicium* tiene el *compromissum*, grupo de estipulaciones con las que dos o más personas se comprometen a pagar una pena si no se someten a la decisión que determinado árbitro, elegido por ellas mismas sin intervención de la

la obligación fuese expuesto en él con palabras libres. Sobre la *q. n. n. p.* véase en particular COLLINET, *Études hist. sur le droit de Justinien*, I, Paris, 1912, ps. 59 y ss.; y KRELLER, *Studi Riccobono*, 2, ps. 357 y ss.

³⁹ Trato de evitar, con una nueva formulación, las finas objeciones de BETTI (“Bull. Ist. Dir. Rom.”, 34, ps. 291 y s.), reforzadas por las interesantes observaciones de BESELER, “Rev. Fundac. Savigny”, 45, p. 238. De cualquier modo, incluyendo en el texto el *iudicium* entre los contratos formales, he agregado “en la concepción romana”. A esta concepción será quizá preferible, *in thesi*, la de la “pura y simple sujeción jurídica a la condena”; pero si queremos darnos cuenta de por qué los romanos reconocieron aquí una *obligatio*, semejante idea no nos ayuda. Para los romanos la *litis contestatio* es un contrato por la misma razón por la cual consta de un grupo de contratos el *compromissum*, es decir, porque queda en su pensamiento, aun en época avanzada, la idea de que las partes deben aceptar la sentencia sólo porque a ello se han comprometido por anticipado.

⁴⁰ Textos en PEROZZI, *Obbl. rom.*, ps. 86 y ss. El mismo PEROZZI (*Istit.*, 2ª ed., II, p. 245) dejó de lado el argumento en contrario que en la primera edición de su admirable *Manual* había sacado de GAYO, III, 180.

autoridad, habrá de pronunciar sobre una o más controversias determinadas⁴¹. Aquí, sin embargo, los romanos no ven más que la unidad de fin, el que hace interdependientes las diferentes estipulaciones; el hecho de que cada una de éstas fuera por sí misma un contrato, no permitía considerar del mismo modo al *compromissum* en su conjunto.

*
* *

A los contratos formales se aproximan ciertos negocios a los cuales el pretor ha provisto de acciones *in factum conceptae*, y que por eso los romanistas llaman, con poco feliz expresión, *pacta praetoria* (o, peor aún, *legitima*). Aunque deba considerarse que, por lo menos en época avanzada, ninguno de ellos exigiese la pronunciación ni la escritura de palabras determinadas, sin embargo estos negocios, nacidos en parte para permitir una *conversión* (cfr. p. 94, n. 6) de contratos verbales nulos por vicio de forma, tienen de común con estos últimos la rigidez de la obligación que nace de ellos, como también la atenuación, o directamente exclusión, del requisito de la causa. Entran en el grupo en examen la *pecunia constituta* y los diversos *recepta*.

8. Se tiene la *pecunia constituta* cuando se promete, con palabras de libre elección, el pago en un día establecido de una deuda preexistente de dinero, propia o ajena; la promesa carecía de efectos si la supuesta obligación no existía, y en todo caso la obligación que nacía del *constituto* no se sustituía a la que preexistía, sino que se agregaba a ella. A las deudas de dinero fueron asimiladas ya por los clásicos las de otras cosas fungibles; JUSTINIANO fué más lejos, admitiendo que cualquier obligación podía ser objeto de *constitutum*. Y él mismo admitió, mediante interpolaciones, que se hiciese la convención antes que en vista del pago, con el fin de que

⁴¹ Acepto la definición de LA PIRA, *Studi Riccobono*, 2, ps. 189 y ss., y con ella la afinidad de estructura entre *compromissum* y *litis contestatio* (cfr. p. 371, nota 39); pero hago toda reserva con relación a las ulteriores inferencias (existencia de fórmulas estipulatorias predeterminadas, poder del árbitro de condenar y absolver, etc.). Sobre el carácter posclásico del compromiso sin cláusula penal, cfr. ROTONDI, *Scr. giur.*, II, ps. 284 y ss.; y ROUSSIER, "Rev. Hist. de Droit", 1939, ps. 167 y ss.

el día fijado se suministraran al acreedor garantías reales o personales⁴².

9. En cuanto a los *recepta*, se distinguen tres tipos:

Ante todo, el *receptum argentarii*, con el cual un banquero se compromete a pagar en determinado día la deuda de un cliente. Aunque alguna expresión de JUSTINIANO (C. 4, 18, 2) haya suscitado largas disputas, parece cierto que la acción otorgada al acreedor contra el banquero fuese pretoria. El banquero quedaba obligado sobre la base de la declaración hecha, independientemente de la real existencia de la deuda originaria del cliente. En la constitución citada, JUSTINIANO, a quien esta última norma pareció repugnante, absorbió el *receptum argentarii* en el *constitutum debiti alieni*, y, en consecuencia, se preocupó por hacer desaparecer del Digesto todo vestigio de él.

El *receptum nautarum cauponum stabulariorum* es una declaración mediante la cual el capitán de una nave mercante o un posadero o el dueño de un establo toma sobre sí la responsabilidad por la destrucción o daño que puedan sufrir las cosas que se le hubieren confiado a él mismo o a su personal, o las que de cualquier manera sean llevadas por el cliente sobre la nave o al albergue, o al establo. Tal responsabilidad encuentra un límite solamente en la hipótesis de la *vis maior cui resisti non potest*⁴³.

El *receptum arbitrii*, en fin, es el contrato por medio del cual el árbitro, elegido de común acuerdo entre las partes mediante *compromissum* (cfr. p. 371), se obliga a pronunciar la decisión.

Aun se discute cuál es el elemento común que unifica a los tres negocios ahora definidos bajo la misma denominación y bajo el mismo título del Edicto. La opinión, muchas veces sustentada, de que en todos ellos el compromiso fuese asumido me-

⁴² Sobre el tema véase ASTUTI, *Studi intorno alla promessa de pagamento*, partes I ("Annali Univ. Camerino", 11, 2, 1937, ps. 81 y ss.) y II (Milano, 1941).

⁴³ El tema es un verdadero semillero de controversias; se discute si el Edicto contemplaba originariamente sólo al *nauta* y cuándo le fueron asimilados el *caupo* y el *stabularius*; si el caso de fuerza mayor exoneraba verdaderamente de responsabilidad; si el derecho clásico haya nunca renunciado a la solemne (o por lo menos explícita) asunción de la responsabilidad. Cfr. por último mi *Responsabilità contrattuale* (2ª ed.: Napoli, 1933), ps. 103 y ss., 271 y s.; SOLAZZI, "Riv. Dir. della Navig.", 2, 1936, ps. 113 y ss.; LUZZATTO, *Caso fortuito e forza maggiore*, 1, Milano, 1938, ps. 157 y ss.

diante una fórmula solemne que contuviera el verbo *recipio*, aunque atrayente, está lejos de haber sido demostrada; antes bien, para el caso del *receptum nautarum*, etc., hay buenas razones para considerar que, por lo menos con el progreso del tiempo, la obligación pudo nacer también de la simple recepción de las mercaderías a bordo o en el albergue o en el establo. Más probable es que el verbo *recipio* fuese usado en la declaración que emitía el *argentarius* al obligarse a pagar por su cliente; la razón por la cual las otras dos convenciones han sido puestas sobre la misma línea, habría que buscarla más bien en la común asunción de una responsabilidad rigurosa e indeclinable⁴⁴.

§ 4. LOS CONTRATOS CONSENSUALES

Concepto general. Los tipos particulares: 1) compraventa; 2) locación-conducción; 3) sociedad; 4) mandato.

Los contratos consensuales, que GAYO (III, 136) opone con particular energía a los formales, y que en las Instituciones Justinianas (3, 22, 1) se oponen también a los reales, son aquellos en los cuales la obligación nace del acuerdo entre las partes, expresado de cualquier manera; mientras no se requiere "neque verborum neque scripturae ulla proprietas" (GAYO), tampoco es necesaria, para que nazca la obligación, la dación de cosa alguna (JUSTINIANO). La libre manifestación del consentimiento importa que los contratos en cuestión puedan concluirse entre presentes y entre ausentes, de viva voz o por carta, personalmente o *per nuncium* (cfr. p. 105, n. 21).

Los cuatro contratos pertenecientes al grupo (compraventa, locación-conducción, sociedad, mandato), son atribuidos por los juristas al *ius gentium*, del que representan el producto más notable. Nacen, en efecto, de las convenciones realizadas en los

⁴⁴ Cfr. sobre el particular PARTSCH, *Der ediktale Garantievertrag durch Receptum* [El contrato edictal de garantía mediante "receptum"], en "Rev. Fundac. Savigny", 29, 1908, ps. 403 y ss., quien pone en relación el verbo *recipere* con el ἀναδέχεσθαι de los documentos griegos, y aproxima las dos primeras formas de *receptum* a contratos helenísticos de garantía.

mercados internacionales entre comerciantes romanos y extranjeros, y encuentran en Roma la primera tutela jurídica en el tribunal del *praetor peregrinus*; sólo posteriormente son acogidos por el derecho civil, y se hacen practicables también entre romanos. De ello deriva también el carácter de buena fe que las acciones que los tutelan han tenido siempre (cfr. ps. 140 y 333): para el contrato de compraventa, son las acciones *empti* y *venditi*, reciprocamente correspondientes según que obre el comprador o el vendedor; para el contrato de locación-conducción, las acciones *locati* (que corresponden al locador) y *conducti* (que pertenecen al locatario); para el contrato de mandato, el *iudicium mandati* y su *iudicium contrarium* que mandante y mandatario pueden intentar, según los casos, uno contra el otro; en fin, para el contrato de sociedad, la *actio pro socio*, ejercible por cada uno de los socios.

*
FRANCIA
* *

1. La *compraventa*. Es un contrato consensual en virtud del cual uno de los contratantes (vendedor) se obliga a transmitir al otro (comprador) la posesión de la cosa, y a garantizarle su pacífico goce, mientras el otro se obliga a transmitir como contraprestación la propiedad de una suma de dinero. La cosa que es objeto de venta se llama *merx*; el dinero con que se la paga, *pretium*.

En la definición que hemos formulado está indicada, ante todo, la característica más original de la compraventa romana, que es la *mera obligatoriedad*. La compraventa clásica no transmite ni la mercancía ni el precio, sino que crea solamente obligaciones, en cumplimiento de las cuales serán transmitidos una y otro. Desde este punto de vista, la compraventa romana es una institución verdaderamente singular en la historia del derecho; cuanto más se extienden nuestros conocimientos en el campo del derecho antiguo comparado, mejor se revela la difusión de la concepción opuesta, en virtud de la cual la venta es, por lo menos *ex parte venditoris*, un negocio jurídico *real*, que transmite inmediatamente la propiedad de la cosa; y la misma concepción domina las legislaciones modernas, aun aquellas que derivan —como la italiana— de tradiciones romanísticas. En Roma misma, por lo demás, el contrato consen-

sual no es originario; sabemos ya que la compraventa del antiguo derecho civil fué la *mancipatio*, cambio inmediato de cosa contra precio (ps. 222 y ss.); y también antes de que ella surgiese debió existir, en el uso del mercado, el cambio puro y simple (natural y monetario), fundado sobre la entrega manual. No sabemos cómo se impuso el principio de la mera obligatoriedad; el origen del *ius gentium*, que nos explica perfectamente esa absoluta falta de formalidades que es propia de la venta, no da, en cambio, la razón de la separación verificada entre la obligación de transmitir la cosa y la transmisión misma; tanto más cuanto que el derecho de los países de civilización griega, en el que se acostumbra a pensar como en el modelo a que más fácilmente podían atenerse las contrataciones entre romanos y extranjeros, permaneció siempre dominado por la idea de la compraventa de efecto inmediato⁴⁵.

Como se ha visto, son elementos objetivos de la venta la cosa y el precio. En cuanto a la primera, la venta es nula si la cosa está *extra commercium*⁴⁶, o ha perecido ya en el momento del contrato, o pertenecía ya al comprador. En cambio, no es nula, por las razones que veremos, la venta de cosa ajena. La mercancía puede estar determinada ya individualmente, ya por su pertenencia a un grupo (por ejemplo, diez barriles de vino de mi cantina); aun cuando nunca esté explícitamente excluida la venta propiamente genérica, el hecho de que ningún ejemplo seguro se encuentre en la rica casuística de nuestras fuentes, hace pensar que ella repugnase a la mentalidad romana, y que para realizar convenciones de esta especie se recurriese, aun en la época clásica, a la estipulación. En los mismos límites de determinación se pueden vender también las cosas futuras: si en su producción entran circunstancias independientes de la voluntad del vendedor, el contrato puede configurarse como *emptio rei speratae*, en la cual

⁴⁵ La opinión más probable es que el carácter exclusivamente obligatorio del contrato consensual derive de que en un primer momento se recurrió, para realizarlo, a la estipulación.

⁴⁶ Esto no impide que si el comprador ignoraba la in comerciabilidad, el vendedor esté obligado a indemnizarlo. Por ello, si se había vendido un hombre libre (en cuyo caso era fácil el error), la venta era considerada válida respecto del comprador *ignorans*; en cambio, si un *locus religiosus* había sido vendido *pro puro*, los clásicos auxiliaban al comprador de buena fe con una *actio in factum*, mientras que los justinianeos aplican también aquí la *actio empti*. Diversos puntos de vista en FERRINI, *Opere*, IV, p. 12; BIONDI, *St. Riccobono*, 4, ps. 1 y ss.; VOCI, *Errore*, ps. 146 y ss.

las partes estarán obligadas solamente si las cosas llegan (y en los límites en que lleguen) a existir (vendo, por ejemplo, la uva de mi próxima vendimia a tanto el quintal), o como *emptio spei*, en la cual el riesgo se trasfiere al comprador (por ejemplo, vendo la misma uva, llegue o no a existir la cosecha, al precio global *x*). Pero naturalmente, un artesano puede también comprometerse a construir para nosotros un objeto, por ejemplo, un anillo o un armario, y si el material es suyo habrá compraventa (mientras que habrá una locación si el material es nuestro). Pueden ser objeto de venta también las cosas incorpóreas; por ejemplo, derechos sobre cosas ajenas (constituídos o a constituirse) y créditos; y hasta las herencias en su conjunto, con tal que estén deferidas, ya que de otra manera se incurriría en la prohibición de los pactos sucesorios.

En cuanto al precio, surgió al principio del Imperio una controversia entre sabinianos y proculeyanos, considerando los primeros que cualquier cosa pudiese desempeñar función de precio respecto a cualquier otra, y los segundos, en cambio, que no hay venta sin dinero (*pecunia numerata*). Pero la teoría de los sabinianos no tuvo éxito, sobre todo por ser inconciliable con la fundamental diversidad que veremos subsistir entre las obligaciones del vendedor y las del comprador. Otro requisito del precio es el de ser determinado (*certum*); la determinación puede hacerse con referencia a una circunstancia objetivamente segura (por ejemplo, el precio por el cual el vendedor mismo compró la cosa, o la suma que se encuentra en el arca del comprador), pero no puede dejarse al arbitrio de las partes ni de un tercero; la posibilidad del *arbitrium* de un tercero se admite sólo en el derecho justiniano, con la condición de que el encargado haga la estimación personalmente. En cuanto a la idea del justo precio, ella se presentó al espíritu de los clásicos solamente en el sentido de evitar que bajo el nombre de la venta se ocultasen donaciones prohibidas (en particular entre marido y mujer); de otra manera, pensaban que correspondía dejar libres a las partes en la tendencia a sacar del contrato la máxima utilidad personal⁴⁷. Una reforma tardía, falsa-

⁴⁷ PAULO, D. 19, 2, 22, 3: "naturaliter concessum est quod pluris sit minoris emere, quod minoris sit pluris vendere, et ita invicem se circumscribere". Una defensa brillante del mismo principio es fácil de leer, suprimiendo las pequeñas interpolaciones, en la constitución de Diocleciano en C. 4, 44, 8.

mente atribuída en constituciones interpoladas del Código a Diocleciano y a sus sucesores, pero, en realidad, justinianeas, se inspiró en la máxima de que el precio no puede ser inferior a la mitad del justo; sin embargo, la máxima es aplicada sólo a las ventas inmobiliarias, y no está acompañada por una máxima inversa favorable al comprador. Si el inmueble fué vendido por un precio inferior a la mitad del justo (*laesio enormis*), se concede al vendedor una acción de rescisión, con la que puede volver a tomar la cosa restituyendo el precio recibido, salvo para el comprador la facultad de conservar el inmueble integrando el precio justo.

Los problemas más delicados surgen a propósito de las obligaciones del vendedor (en cuanto al comprador, todo se reduce a transferir a la contraparte la propiedad de las monedas). Los juristas insisten, en efecto, con particular energía, en excluir que el vendedor esté obligado a transferir la propiedad de la cosa, y hasta niegan el carácter de venta a una convención en la cual se haya tomado el compromiso explícito de transferirla⁴⁸; la obligación del vendedor es, más bien, de transferir al comprador la posesión, y de asumir con un contrato aparte (estipulación) la obligación de asistirlo y, eventualmente, indemnizarlo en el caso de que un tercero reivindique la cosa en su contra (evicción). La primera consecuencia es la ya referida validez de la venta de cosa ajena. Una segunda consecuencia, la de que en caso de venta de cosas *mancipi* el vendedor no esté obligado al acto solemne de transmisión (*mancipatio* o *in iure cessio*), resulta claramente de ciertos pasajes, en particular del celeberrimo de PAULO en D. 19, 4, 1 pr.; si en otros lugares se habla de *mancipatio* cumplida o a cumplir, esto parece referirse a un compromiso resultante de acuerdo especial, y las *mancipationes* textuales conservadas parecen más bien sustituir que ejecutar los contratos consensuales ya concluídos entre las

⁴⁸ Cfr. CELSO, D. 12, 4, 16, y el admirable estudio de V. SCIALOJA en "Bull. Ist. Dir. Rom.", 19, 1907, ps. 161 y ss. = *St. giur.*, II, ps. 247 y ss. Sobre las obligaciones del vendedor cfr. MONIER, *Le caractère de bonne foi du contrat de vente et l'obligation de manciper*, en *Mélanges Cornil*, 1926, 2, ps. 139 y ss.; RICCA-BARBERIS, *L'evizione obbligo-limite del venditore romano*, en *Studi Bonfante*, 2, ps. 129 y ss.; BUSSMANN, *L'obligation de délivrance du vendeur*, Lausanne, 1933; ARANGIO-RUIZ, *Diritto puro e diritto applicato negli obblighi del vend.*, en "Festschr. Koschaker", 1939, II, ps. 141 y ss.

partes⁴⁹. Por lo demás, no es difícil darse cuenta de este régimen, por singular que parezca. La venta es un contrato del *ius gentium*, nacido en las relaciones entre comerciantes romanos y extranjeros; ahora bien: a éstos no les eran accesibles los actos solemnes requeridos en Roma para la transferencia de la propiedad sobre las *res Mancipi*, y había que conformarse, en consecuencia, con recibir su posesión pacífica. Igualmente, cuando el nuevo contrato fué aceptado en las relaciones entre romanos, nada imponía que se cambiara su estructura; en efecto, los romanos podían siempre recurrir —si lo querían— a sus actos solemnes, *mancipatio* y *stipulatio*, con los cuales transferían la propiedad o se comprometían a transferirla, mientras que si recurrían a la compraventa con la sucesiva *traditio* les beneficiaba la rápida adquisición de la propiedad por usucapión (ps. 230 y ss.). La idea de hacer seguir la *mancipatio* a la compraventa consensual, a fin de unir las ventajas de la antigua venta al contado con las del nuevo contrato obligatorio, es un invento de la práctica, aplicado por cierto ampliamente pero sin renegar de las diferencias de estilo y de fin que mediaban entre las dos instituciones. La mejor prueba de este desarrollo está, a mi entender, en el cuidado que el pretor puso en defender al comprador que hubiese recibido la simple tradición (propietario pretorio, cfr. ps. 205 y ss.); pero quizá tan probatorio como éste es el hecho de que, aun cuando el uso del acto solemne de transmisión se hubo divulgado, la necesidad en que el vendedor se colocaba de ejecutarlo no excluía aquella otra, derivada del derecho objetivo, de transferir con acto aparte la *vacua possessio*.

De cualquier manera, si de la cosa *nec Mancipi* se había hecho la tradición o de la cosa *Mancipi* (en ejecución del acuerdo especial de que se ha hablado) la *mancipatio* o la *in iure cessio*, y si el vendedor era propietario y romanos ambas partes, había cuanto bastaba para que la propiedad pasase. Es verdad que un célebre pasaje de las Instituciones justinianeas (2, 1, 41) afirma que la propiedad no pasaba si no se había pagado el precio, o si por lo menos no se hubiesen dado garantías en este sentido; y la máxima está repetida en algún fragmento del Digesto. Pero por un lado se encuentran, en el mismo Digesto, otros pasajes donde la máxima es

⁴⁹ Véase en mis *Negotia*, los n.ºs. 87 a 90; la estructura del contrato consensual, seguido de *traditio*, es, en cambio, evidente en los n.ºs. 132 y 136.

explícitamente negada; y por el otro, está muy de acuerdo con el sentimiento jurídico griego y demasiado en contraste con la neta separación que tiene lugar en Roma entre negocios obligatorios y traslativos, como para que no surja espontáneamente la sospecha de la falsificación. El argumento más decisivo se saca de varios rescriptos imperiales del siglo III, originados por vendedores provinciales que, no habiendo recibido el precio, pretendían haber conservado la propiedad de la cosa; los emperadores rechazan tales pretensiones, remitiendo a los interesados a la acción *in personam* (*actio venditi*) destinada a reclamar el precio⁵⁰.

En el capítulo XVII se tratará de los criterios acerca de la responsabilidad del vendedor (*dolo y custodia*). Aquí se observará solamente que si la cosa se pierde por fuerza mayor, por ejemplo, en caso de muerte natural del esclavo o de descomposición del vino, las fuentes afirman que el riesgo pertenece al comprador (*periculum est emptoris*), y que éste se halla, en consecuencia, obligado a pagar igualmente el precio. La máxima nos deja perplejos; aparte de las consideraciones de equidad, a muchos parece poco elegante que mientras el paso de la disponibilidad de la cosa tiene lugar solamente a partir de la tradición, y mientras la adquisición de la propiedad queda con frecuencia postergada hasta el cumplimiento de la usucapión, el comprador deba soportar el riesgo de la pérdida desde el día del contrato.

Quizá la regla es el residuo de una originaria y recíproca independencia entre las obligaciones de las dos partes; quizá tam-

⁵⁰ Cfr. PRINGSHEIM, *Kauf mit fremdem Geld* [Compra con dinero ajeno], Leipzig, 1916; y las réplicas a sus críticos en "Rev. Fundac. Savigny", 50, 1930, ps. 333 y ss., y 53, 1933, ps. 491 y ss. Entre los contradictores, hay quien considera que en el derecho clásico el principio de las Instituciones valía para todos los actos mediante los cuales se trasfería la propiedad (APPLETON, "Rev. Hist. de Droit", 4ª serie, 7, 1928, ps. 173 y ss.); quien cree que se aplican sólo a la tradición (MEYLAN, *Studi Bonfante*, 1, ps. 441 y ss., y ROMANO, *Nuovi studi sul trasferimento de la proprietà*, etc., Padova, 1937); quien, en cambio, querría hacer de ella una regla especial de la *mancipatio* (ALBERTARIO, "Riv. di Dir. Comm.", 27, 1929, 1ª parte, ps. 233 y ss. = *Studi di dir. rom.*, III, Milano, 1936, ps. 425 y ss.; ARCHI, *Il trasferimento della proprietà nella compravendita romana*, Padova, 1934). Yo me adherí a PRINGSHEIM desde la primera edición de estas *Instituciones* (1921); y un curso especial sobre la venta, impartido en la Universidad egipcia, ha robustecido mi persuasión. En cuanto a la cita de las XII Tablas en I, 2, 1, 41, es buena conjetura de BESELER (*Acta Congr. iurid. internat.*, 1, ps. 335 y ss.) que la regla de la antigua ley contemplase la *obligatio auctoritatis*.

bién, como COLLINET me señalaba en una interesante discusión privada, se trató originariamente de evitar al comerciante vendedor los riesgos de la navegación. De cualquier manera, la tentativa que varios escritores han hecho para atribuir al derecho clásico el principio opuesto, es decir, que el riesgo pase solamente cuando la posesión haya sido trasferida o cuando el comprador mismo esté en retraso para retirar la cosa, debe considerarse fracasada por defecto de demostración⁵¹. Por lo demás, se observa que la máxima *periculum est emptoris* tiene sus correctivos; en primer lugar, el acto de la autoridad que pone la cosa *extra commercium* o la expropia, libera a ambas partes; en segundo lugar, la responsabilidad del vendedor por la custodia delimita rigurosamente los casos de fuerza mayor que quedan a cargo del comprador; en fin, las partes son libres de disponer diversamente, y sabemos que la asunción explícita del riesgo por parte del vendedor era frecuente para las mercaderías deteriorables, en especial en el ejemplo ya citado del vino.

La obligación de resarcir el daño derivado de la evicción no nace directamente del contrato consensual. En el más antiguo derecho, la garantía era, como a su tiempo se dijo (ps. 224 y 230), una consecuencia de la *mancipatio*. En efecto, el *mancipio accipiens* que no pudiese invocar todavía en su favor el trascurso del término de la usucapión tenía facultad, si era citado a juicio por un tercero reivindicante, de llamar a la causa al *mancipio dans*, y éste estaba obligado a intervenir en el proceso en apoyo de su causa-habiente (en cuya función se le decía *auctor*, como *auctoritas* a su intervención); si se rehusaba, o si no obtenía el resultado, la *actio auctoritatis* del comprador lo obligaba a pagar el *duplum*⁵².

⁵¹ La tentativa la hizo por primera vez nuestro ARNÓ, *La teoría del per. rei venditae nel dir. rom. class.*, en "Giur. Ital.", 49, 1897, 4, ps. 209 y ss., y en varios artículos complementarios; después renovada con gran estilo en el elegante escrito de F. HAYMANN, *Textkritische Studien zum röm. Obligationenrecht* [Estudios de crítica textual sobre el derecho romano de las obligaciones], II. *Periculum est emptoris*, en "Rev. Fundac. Savigny", 41, 1920, ps. 44 y ss.; cfr. también BESELER, *Rev. d'Hist. du Droit* (holand.), 8, 1928, ps. 279 y ss. Véase, sin embargo, las críticas vigorosas de RABEL, "Rev. Fundac. Savigny", 42, 1921, ps. 349 y ss.; y de SECKEL y LEVY, *ibid.*, 47, 1927, ps. 117 y s. (en la réplica de HAYMANN en el vol. 48, ps. 314 y ss.).

⁵² Esto es claro y nítido; y es clara también la analogía con la *auctoritas tutoris* (p. 563) y con la *auctoritas patrum* del derecho público (Storia, 5ª ed., p. 41 y *passim*), que también sirvieron para convalidar

En *mancipationes* con fines de venta, se encuentra testimoniada también una *satisfactio secundum Mancipium*, que parece sirviese para someter al régimen de la estipulación las obligaciones ya recordadas⁵³. En el régimen del contrato consensual, que —como se ha visto— no imponía, en general, la *mancipatio*, figuraba entre las obligaciones del vendedor la de llegar a una especial estipulación de garantía, cuya consecuencia era que, verificándose la evicción, se pudiese obrar contra él *ex stipulatu*. Los formularios diseñados a este fin por la jurisprudencia cautelar, reproducidos después, por lo menos en parte, en los edictos de los pretores y de los ediles curules, eran varios: estaba la *stipulatio habere licere*, con la que se garantizaba el evento de la posesión pacífica, dejando a la discreción del juez establecer, en caso de producirse la evicción, el monto de la condena; y estaba la *stipulatio duplae*, la más difundida entre todas, con la cual el vendedor se obligaba a pagar el doble del precio cuando se produjese el evento previsto.

Del hecho de que el cumplimiento del negocio jurídico de asunción de garantía esté entre las obligaciones del vendedor deriva que, si él se rehusa a cumplirlo, el comprador puede intentar la *actio empti* para constreñirle a hacerlo; pero en los orígenes el comprador que hubiese omitido hacer valer este derecho suyo, nada tenía que pretender si imprevistamente lo sorprendiese la evicción. Más tarde se admitió que el vendedor debiese, sin embargo, resarcirle el daño derivado de su incumplimiento; lo que equivalía a decir que con la acción contractual (*empti*) se obtenía una indemnización análoga a la que se habría podido pretender con la *actio ex stipulatu* en caso de haberse realizado una estipulación. Se discute el criterio sobre cuya base la indemnización fuera calculada en este caso; sin embargo, parece que el comprador obtuviese lo que le habría procurado la menos pingüe entre las estipulaciones en uso, es decir, la *stipulatio habere licere*.

Se considera evicción no sólo la reivindicación de la cosa, sino también la *vindicatio ususfructus* o *servitutis*; naturalmente,

declaraciones de voluntad por una u otra causa ineficaces. Las diversas teorías sobre la *auctoritas* que autores recientes van lanzando en el mercado pertenecen a aquella mística del derecho primitivo, inaccesible con los métodos de la razón, que se va poniendo peligrosamente de moda.

⁵³ Nueva doctrina en MEYLAN, *La s. s. m.*, en "Rev. Hist. de Droit", 1948, ps. 1 y ss.

las relativas indemnizaciones se proporcionan al daño sufrido por el comprador⁵⁴.

También el régimen de la garantía por los vicios ocultos de la cosa vendida se ha ido formando por diversas vías. Para cada orden de *res Mancipi* las declaraciones del vendedor en el acto de la *mancipatio*, para todas las cosas los compromisos que asumía con especiales estipulaciones, atribuían al comprador acciones judiciales; y cada vez más se fué difundiendo en la práctica el hábito de fundir las garantías para la evicción y para los vicios en la ya citada *stipulatio duplae*. Pero para las ventas de esclavos y de animales, los ediles curules impusieron al vendedor declaraciones explícitas, y para el caso de que éstas resultaran falsas o de que se encontraran vicios no declarados, dieron al comprador la elección entre dos acciones, ambas de brevísima duración: la redhibitoria, con la cual conseguía la devolución del precio restituyendo la cosa, y la estimatoria, o *quantum minoris*, con la cual obtenía una suma correspondiente a la depreciación de aquélla. Por lo demás, hay una tendencia de la jurisprudencia clásica, paralela a la señalada en materia de evicción, a comprender también la responsabilidad por los vicios en el campo de la acción contractual (*actio empti*), por lo menos cuando los vicios fuesen conocidos por el vendedor⁵⁵.

De la venta griega deriva la institución de las arras (*arrha*, ἀρραβών), aunque haya sido, por lo menos en un primer tiempo, adaptada a los principios romanos. Las arras griegas consistían en la entrega anticipada de una parte del precio, o de un objeto precioso, hecha al poseedor de una cosa por quien se proponía com-

⁵⁴ Sobre el tema de la evicción, cfr. para todos GIRARD, en varios estudios reunidos en sus *Mélanges de dr. rom.*, 2, París, 1923; RABEL, *Die Haftung des Verkäufers wegen Mangels im Rechte* [La responsabilidad del vendedor por defecto de derecho], Leipzig, 1902; DE RUGGIERO, *I papiri greci e la stip. duplae*, en "Bull. Ist. Dir. Rom.", 14, 1901, ps. 93 y ss.; KASER, *Das Ziel der "actio empti" nach Eviktion* [El fin de la "actio empti" como consecuencia de la evicción], en "Rev. Fundac. Savigny", 54, 1934, ps. 162 y ss.

⁵⁵ Sobre los particulares, cfr. en especial HAYMANN, *Die Haftung des Verkäufers für die Beschaffenheit der Kaufsache* [La responsabilidad del vendedor por el estado de la cosa vendida], Berlín, 1912; MONIER, *La garantie contre les vices cachés dans la vente rom.*, París, 1930; y por último la difundida exposición de (JOERS-) KUNKEL, *Römisches Recht*, ps. 233 y ss. Para la extensión justiniana de las acciones edilicias a la venta de cualquier mercadería, ver DE SENARCLENS, "Rev. Hist. de Droit", 4ª serie. 5. 1926, ps. 572 y ss.

prarla, con el efecto de que, si modificaba su proyecto, perdía lo que había dado, mientras que el vendedor que cambiase de parecer debía restituir el doble (u otro múltiplo) de las arras recibidas. En cambio, en Roma, las arras fueron acogidas solamente como medios de prueba del contrato consensual ya en sí perfecto en el sentido de que vendedor y comprador pudiesen en todo caso pretender la ejecución integral; de allí el nombre de *arrha confirmatoria*. Pero una constitución de JUSTINIANO (C. 4, 21, 17) volvió a la tradición griega, considerando a las arras como dadas "*super facienda emptione*", y reconociendo a ambas partes, salvo acuerdo en contrario, la facultad de desistir unilateralmente del pacto con la pérdida de las arras o con su restitución *in duplum* (*arrha poenitentialis*)⁵⁶.

Al contrato de compraventa pueden agregarse diversas cláusulas accesorias, dirigidas a eliminar sus efectos, sea antes o después de la ejecución, cuando se produzcan determinadas circunstancias. Tales son:

α) la *lex commissoria*, en virtud de la cual el contrato queda como no hecho y el comprador debe restituir la cosa si no paga el precio en un plazo determinado;

β) la *in diem addictio*, en virtud de la cual la venta queda sin efecto si dentro de cierto plazo el vendedor recibe mejor oferta;

γ) el *pactum displicentiae*, por el cual el comprador se reserva la facultad de restituir la cosa y reclamar la devolución del precio si aquella no resulta de su agrado;

δ) el *pactum de retroemendo*, por el cual el vendedor se reserva la facultad de volver a adquirir la cosa dentro de cierto término, por el mismo precio.

Al estudiar los efectos de la condición resolutoria (ps. 100 y ss.), hemos visto cómo se regulaba la ejecución de los más frecuentes de estos pactos.

*
* *

2. La *locación-conducción*. Es un contrato consensual, en virtud del cual una de las partes (locador) se obliga a poner a dis-

⁵⁶ Sobre el tema, más bien complicado que aclarado por buena parte de la reciente literatura, cfr. las seguras directivas de PARTSCH; Scritti inediti e rari, ps. 262 y ss.

posición material de la otra (locatario) cierta cosa que aquélla se obliga a restituir luego de haber gozado de ella por cierto tiempo o después de haberla trabajado o transformado de la manera convenida; según las diversas hipótesis, corresponde al locador o al locatario el equivalente de una suma de dinero llamada *merces*.

La definición que formulamos no corresponde a la doctrina dominante, según la cual el nombre de la locación-conducción es común a tres contratos diferentes:

a) *locatio conductio rei*, consistente en ceder a otro el goce temporario de una cosa mediante el equivalente de una *merces*;

β) *locatio conductio operarum*, que consiste en poner a disposición de otro, por cierto tiempo, los propios servicios, a cambio del pago de una *merces*;

γ) *locatio conductio operis*, consistente en prometer a otro, siempre mediante el pago de una *merces*, toda la actividad necesaria para alcanzar determinado resultado de trabajo (por ejemplo, la construcción de una casa o de un anillo, el transporte de personas o cosas, el lavado de ropa blanca).

Basta leer las pocas líneas que GAYO dedica a la *locatio conductio* (III, 142 y ss.), o recorrer en el Digesto el título respectivo (19, 2) para verificar que ésta no es la concepción de los romanos. No sólo ellos no hacen nunca explícitamente esa distinción (que, sin embargo, sería esencial para orientarse), sino que tratan sin orden los casos que la doctrina moderna separa según su correspondencia a cada uno de los tres tipos. Sobre todo no establecen ninguna diferencia entre *locatio conductio rei* y *operis*: quien *locat* es siempre el propietario o poseedor de una cosa, y objeto de la locación es siempre la cosa misma. Sólo que, mientras en algunos casos ella es locada para que el locatario la goce o perciba sus frutos (*locare rem utendam*; GAYO, III, 144; o *fruendam*, C. 4. 65, 6; o *fundum fruendum*, D. 19, 2, 25 § 1), en otros lo es para que el locatario la transporte (*vinum transportandum, mulierem vehendam locare*), o la limpie (*vestimenta polienda*), o, tratándose de un esclavo, lo instruya en un oficio o en un arte (*servum docendum*). Incluso cuando se habla de *insulam aedificandam*, o, en general, de *opus faciendum locare*, no es objeto del contrato la actividad del artífice, sino el material que le entrega el locador. No hay, pues, que maravillarse porque, distinguiendo sutilmente

entre la posición del lavandero y la del joyero, el viejo ALFENO (D. 19, 2, 31) diga "*rerum locatarum duo genera esse*": donde los modernos verían más bien dos diversas especies de *locatio operis*.

En cuanto a la *locatio operarum* es evidente que representa, en la economía de los antiguos, una excepción frente a la más difundida locación de esclavos de trabajo; así como en estos casos la expresión "*operas servorum locare*" se ha cambiado con la otra "*servos locare*", también cuando, excepcionalmente, se recurría al trabajo libre, se ha hablado de *se operasque suas locare*, y después, simplemente de *operas suas locare*; tanto más cuanto que también en otros campos, y particularmente en las relaciones entre patrono y liberto, los servicios a prestarse por día se consideraban de la misma manera que las cosas fungibles, o, más bien, que el dinero.

No es, pues, como ordinariamente se considera, una analogía de función económica la que ha reunido a los tres tipos en cuestión; es más bien la simple circunstancia, originariamente común a todos los tipos, de la entrega de una cosa para un fin oneroso la que ha dado nombre al contrato. Que los romanos no hayan advertido nunca la oportunidad de separar este contrato en tres, y ni siquiera la de distinguir los casos en que la dación se hace en interés del locatario, de aquellos en que lo es en interés del locador, los casos en que la obligación de la *merces* pesa sobre uno de ellos, de aquellos en que recae sobre el otro, es tan singular como el esfuerzo de los legisladores modernos por mantener unidos bajo el nombre de la locación, los tres diversos contratos antes definidos; sólo en la legislación más reciente (por ejemplo, en el Código italiano de 1942) este estéril esfuerzo ha sido abandonado⁸⁷.

Elementos esenciales del contrato de locación son: la cosa (o las *operae*, también ellas consideradas en el mismo plano que las cosas) y la *merces*. La cosa puede ser, correspondientemente con la variedad de sus funciones en las figuras particulares, consumi-

⁸⁷ La concepción expuesta parece coincidir con la sugerida por PARTSCH y enseñada por RABEL, *Lineamenti*, p. 465; salvo que, mientras se diría que PARTSCH considera la *locatio conductio* unitaria como un primer estadio de desarrollo, ella es, en mi opinión, concepción clásica. Mi orden de ideas está en la base del estudio de BRASIELLO, "*Riv. Ital. Sc. Giur.*", nueva serie, 2-3, 1927-1928, y se abre cada vez más camino; véase, por último, OLIVIER MARTIN, "*Rev. Hist. de Droit*", 4ª serie, 15, 1936, ps. 419 y ss. (interesante en particular para la formación del dogma moderno).

ble o no consumible (piénsese en los contratos de transporte, en el grano dado para moler, en la uva entregada para pisar); se entiende que para que se tenga una *res utenda* (o *fruenda*) *locata* (locación de cosas en el sentido de la dogmática moderna) el objeto debe ser no consumible, salvo reservas análogas a las hechas en materia de comodato (p. 350). Puede también ser locado el ejercicio de *iura in re aliena*, como el usufructo y la superficie. No entra, en cambio, en los términos de la *locatio conductio* el contrato por el cual alguien asume la obligación de desarrollar una actividad diversa del transporte o manipulación de cosas. En estas hipótesis los romanos se hallaban frente a la alternativa de considerar la relación desde el punto de vista de la prestación de servicios (*operae*), o de negarle la calificación de locación; de ahí la exclusión de nuestro contrato, sea respecto de las obras liberales, sea para la actividad desplegada por el agrimensor que señala los límites de los fundos y por el *politor* (agronomo) que dirige su cultivo.

En cuanto a la *merces*, su pago corresponde a aquel que saca provecho de la *locatio*: al *conductor* en los casos de la *locatio operarum* y de la *locatio rei utendae* o *fruendae*, al *locator* en los casos de *locatio rei vehendae* o *poliendae*, *insulae faciendae*, etc. Ella consiste necesariamente, como el precio en la compraventa, en una suma determinada; hace excepción la *colonia partiaria*, en la que el locatario del fundo está obligado a entregar una parte del producto⁵⁸.

A cambio de la *merces*, el locador de *res utenda* o *fruenda* está obligado a entregar la cosa en buen estado y a dejarla disfrutar por el tiempo fijado en el contrato; el locador de servicios y el que toma a su cargo la ejecución de una obra están obligados a desarrollar la actividad prometida. En el caso particular del contrato de transporte marítimo, esta obligación importa que cuando por las necesidades de la navegación, las cosas de alguno de los locadores deban ser sacrificadas, el capitán o armador están obligados a repartir el daño proporcionalmente entre los interesados:

⁵⁸ Sobre la concepción de la *colonia partiaria* en el derecho clásico y en el justiniano, cfr., en diverso sentido, FERRINI, *Opere*, 3, ps. 1 y ss.; LONGO, *La natura della mercede nella loc. cond.*, en *Mélanges Girard*, II, ps. 105 y ss.

prescripción que se vincula a la *lex Rhodia de iactu* (νόμος 'Ροδίων ναυτικός) que se ha hecho norma común del mundo griego y de aquí trasladada al *ius gentium*⁵⁹.

Tanto en la *locatio operarum* como en la *locatio operis faciendi*, la muerte del obrero o del artífice extingue por derecho clásico la obligación. En el derecho justiniano se tiene en cuenta, en la segunda especie, que haya sido o no razón del contrato la habilidad personal del artífice elegido, y solamente en el caso afirmativo se considera extinguida la obligación.

Particular importancia tiene la locación de inmuebles con fines de goce, en la que se da al locatario el nombre de *colonus* si se trata de un terreno, de *inquilinus* si de un edificio. El locatario está obligado, fuera del pago de la *merces* (que es periódica —por lo común, anual o mensual), también a abstenerse de deteriorar de cualquier manera el inmueble. Aun si lo abandona antes del tiempo convenido, queda obligado por toda la *merces*; solamente el derecho justiniano limita la responsabilidad al daño efectivamente sufrido por el locador. En cambio, puede permanecer en el fundo o en la casa después del término fijado, si el locador no se opone; en este caso, se entiende que el inmueble ha sido vuelto a tomar en locación (*reconductio tacita*) por un año si se trata de un terreno, por tiempo indeterminado —y en consecuencia con facultad de cada una de las partes de disolver la relación cuando quiera— si de un edificio. Por incumplimiento de las obligaciones recíprocas, se otorga a ambas partes el derecho de rescisión.

Conforme a la concepción romana de la obligación y del contrato en particular, la relación entre locador y locatario no se transmite sino por herencia; si la cosa es transmitida a título particular, el adquirente no queda vinculado hacia el locatario. Sin embargo, subsiste la obligación del locador de asegurar el goce de la cosa, que se transforma en obligación de resarcir el daño sobrevenido al locatario por la oposición del nuevo propietario.

*

* *

⁵⁹ Sin embargo, DE MARTINO ("Riv. del Dir. della Navig.", 3. 1937. 335 y ss., y 4. 1938. 3 y ss.) considera que la *lex Rhodia* es una invención posclásica.

3. La *societas*. Es un contrato consensual y bilateral⁶⁰, por el cual dos o más personas se obligan a poner en común bienes y trabajo para la obtención de resultados ventajosos para todos. El aporte de los socios puede ser diverso, no sólo cuantitativamente, sino también cualitativamente, en el sentido de que alguno contribuya con bienes y otro emplee en ventaja común su actividad; ganancias y pérdidas se distribuyen según las disposiciones tomadas, o, si éstas faltan, por partes iguales. Está prohibida la *societas leonina*, por la cual alguno de los socios deba dividir con los otros las pérdidas y no las ganancias; en cambio, se admite la exclusión de alguno de las pérdidas.

Cuando —y es el caso más frecuente— la sociedad tiene por objeto la explotación en común de determinados bienes, esto puede ocurrir de dos modos: o en el sentido de que se ponga en común la propiedad, creando mediante tradiciones o *in iure* cesiones parciales una copropiedad, o en el sentido de que se repartan las utilidades que cada uno de los socios obtenga de aquellos bienes.

Los tipos más difundidos y característicos de sociedad en Roma son: la *societas omnium bonorum* y la *societas unius negotiationis*, nacidas —según parece— en diferentes épocas y de diferentes exigencias, pero unificadas después bajo el mismo régimen contractual. La primera parece vincularse al *consortium* familiar (cfr. p. 251), difundida antiguamente entre los hermanos que, convertidos en *sui iuris* a la muerte del padre, continuaban gozando del patrimonio en el estado de indivisión; gracias al reciente

⁶⁰ Es más; es éste el único contrato a que se podría dar el nombre de *plurilateral*, ya que en él pueden intervenir más de dos personas con intereses diversos y eventualmente en conflicto. De un texto atribuido a MODESTINO (D. 17, 2, 4 pr.) y por una frase sibilina en GAYO (III, 154), muchas veces se ha sacado la convicción de que al lado de la *societas consensus contracta* hubiese una *re contracta*, que se identificaría con la que las Instituciones de Justiniano (3, 27 § 3) colocan entre los cuasi contratos y que la ciencia llama *communio incidens* (cfr. por último, EIN, "Bull. Ist. Dir. Rom.", 39, 1931, ps. 76 y ss.; y FREZZA, "Riv. Ital. Sc. Giur.", nueva serie, 7, 1932, ps. 108 y ss.). En realidad, el pasaje de GAYO, cuyo texto exacto nos ha sido ahora restituído por uno de los nuevos pergaminos egipcios, no contempla ni explícita ni implícitamente la pretendida *soc. re contr.* o la comunión; y esto confirma la interpolación muchas veces sospechada en el pasaje de MODESTINO. Se trata de una teoría posclásica, que las escuelas han introducido en algún texto y contra la cual JUSTINIANO ha reaccionado retornando (con modificaciones más aparentes que profundas) al concepto clásico. Cfr. mi estudio: *Soc. re contr. e comm. inc.*, en *Studii Riccobono*, 4, ps. 357 y ss.

descubrimiento de fragmentos gayanos que faltaban en el manuscrito de Verona sabemos que también los extraños podían ligarse en un consorcio análogo, reconociéndose solemnemente como consortes en un proceso ficticio semejante a la *in iure cessio*. La segunda nace, según parece, del comercio internacional, y sirve para realizar con fuerzas unidas una o más operaciones del comercio, por ejemplo, la compraventa de esclavos, citada por GAYO (III, 148), o el préstamo a interés, a que se refiere uno de los famosos tripticos de Transilvania⁶¹. La construcción como contrato consensual y la acción de buena fe se refieren al segundo tipo, pero del primero derivan las reglas más características del contrato, y sobre todo aquella especie de *fraternitas* en que la sociedad se inspira. De él descende, aparte de la amplísima comprensión de la *societas omnium bonorum*, también el principio de que la sociedad se extingue por el recesso unilateral del socio, por la muerte, por la *capitis deminutio*; un régimen que corresponde al de otra institución que tiene sus raíces en la organización familiar, el usufructo (cfr. p. 268). Por lo demás, los efectos de la *capitis deminutio* pueden evitarse al continuar las partes comportándose como socios, lo que dada la estructura consensual del contrato vale como constituir una nueva sociedad. De la misma procedencia familiar deriva el principio de que la condena pronunciada como consecuencia del ejercicio de la *actio pro socio* está limitada *in id quod facere socius potest*, es decir, en los confines de su disponibilidad patrimonial (el llamado *beneficium competentiae*), y de que, por lo demás, esta condena, fundada sobre la conducta dolosa, sea causa de infamia.

La sociedad se extingue también por la obtención del fin para el cual fué constituida, por la destrucción de las cosas que eventualmente se hayan puesto en común, porque éstas se trasformen en no comerciales, o por el vencimiento del término.

*
* *

⁶¹ Cfr. mis *Negotia*, n° 157. Sobre esta duplicidad de origen, y, en particular, sobre la concepción primigenia de la sociedad, cual se refleja —fuera del nuevo Gayo— en el sistema de libros *ad Sabinum*, cfr. la excelente investigación de WIEACKER, *Societas*, I, Weimar, 1936; en la cual, sin embargo, me parece colocada demasiado tarde (en la época de la redacción de las Instituciones de Gayo) la inclusión de la sociedad entre los contratos consensuales.

4. El *mandato*. Es un contrato consensual en virtud del cual una de las partes se obliga a hacer gratuitamente algunas cosas que la otra le encarga. Frecuentemente la actividad a que el mandatario se obliga tiene carácter jurídico (por ejemplo, comprar o vender en el mercado en interés del mandante, sostener sus razones en un litigio, etc.); pero puede también ser de cualquier otro género, de manera que hay casos en los cuales sólo la gratuidad distingue el mandato de la locación (sería, por ejemplo, mandato —dice GAYO, III, 162— el contrato por el cual alguno se comprometiese a lavarme gratuitamente la ropa blanca).

El mandato puede tener lugar, sea —y es el caso más frecuente— en interés del mandante, sea en interés de un tercero, y no importa que con el interés de uno o del otro concorra eventualmente un interés del mandatario; en cambio, no sería mandato, sino *consilium* no productivo de obligación, la exhortación dirigida a otro para que haga alguna cosa en su propio interés. Sobre el llamado *mandatum qualificatum* o *mandatum pecuniae credendae* (mandato de prestar dinero a otro con efecto de garantía de la obligación), ver *infra*, p. 455.

Diverso es el concepto de la procuración. *Procurator* es, en el significado predominante, el administrador de un patrimonio (*procurator omnium bonorum*); y es, por lo común, un liberto que se considera investido de la función más por acto unilateral del patrón que por contrato; frente a los extraños, su investidura es más de hecho que de derecho. Sucesivamente, el pretor reconoció el carácter de *procurator* a quien asumiese el encargo de representar a otro en un proceso (*procurator ad litem*). La acción que regulaba la relación entre el *procurator omnium bonorum* y el *dominus negotii* era la *actio negotiorum gestorum*, mientras que al *procurator ad litem* se lo consideraba como un mandatario. Sólo el derecho justinianeo admite para toda especie de encargos el *procurator unius rei*, y considera tanto a éste como al *procurator omnium bonorum* mandatarios, si hubo encargo expreso, y *negotiorum gestores* (cfr. p. 399) si no lo hubo; hasta se terminó por llamar *verus procurator* al que hubiera sido investido mediante mandato, y *falsus procurator* al que hubiera intervenido espontáneamente⁶².

⁶² Sobre el desarrollo histórico descrito, cfr. especialmente BONFANTE, *Facoltà e decadenza del procuratore romano*, en *Scritti giuridici varii*, III, ps. 250 y ss.; ALBERTARIO, *Studi nelle scienze giuridiche e sociale dell'*

El mandato entra en la categoría de los contratos imperfectamente bilaterales, en el sentido ya visto para el depósito, el comodato y la prenda. De él surge, en efecto, sólo esencialmente la obligación del mandatario de cumplir el encargo, pero puede surgir también la obligación del mandante de indemnizar al mandatario por los gastos hechos y por los daños sufridos en la ejecución, y de aceptar las consecuencias de la gestión⁶³. Especialmente en este último sentido, la obligación eventual del mandante tiene tal frecuencia que hace que se la pueda considerar como normal; por eso consideran algunos estudiosos que la acción pudiese intentarse en forma doble, con fórmula basada sobre el *quidquid alterum alteri dare facere oportet ex fide bona* y con la consiguiente posibilidad de que, según el resultado de la compensación, se condenase a una o a la otra parte. Me parece más probable que las dos acciones fuesen distintas (*directa* la del mandante y *contraria* la del mandatario), salvo la posibilidad de intentarlas juntas, llevándolas a conocimiento del mismo juez⁶⁴.

Como se vió (p. 106), la exclusión de la representación directa hacia que del contrato concluido por el mandatario con un tercero en cumplimiento del encargo que se le había conferido, no surgiesen relaciones de derecho y obligación entre mandante y tercero, sino sólo entre éste y el mandatario. Pero el mandatario puede, con la *a. mandati contraria*, pretender que el mandante lo indemnice también de la condena sufrida si por falta de fondos suministrados por éste no ha podido hacer frente a sus compromisos, y el mandante puede, si el mandatario no ha sido diligente en hacerse pagar por el tercero, intentar contra él la *actio mandati directa* para constreñirlo a ejercer los remedios respectivos o a cedérselos eventualmente en el sentido que veremos (ps. 448 y ss.).

Istituto di Pavia, 6, 1921, ps. 87 y ss. = *Studi di dir. rom.*, III, ps. 495 y ss.; SOLAZZI, "Rend. Ist. Lomb.", 56, 1923, ps. 142 y ss., 735 y ss.; 57, 1924, ps. 302 y ss.; "Atti Accad. Napoli", 58, 1937, ps. 19 y ss.; FRESE, *Mélanges Cornil*, I, ps. 325 y ss., y *Studi Bonfante*, 4, ps. 397 y ss.

⁶³ Tal, por lo menos, es el dogma justiniano; que los clásicos pusieran las obligaciones recíprocas bajo el mismo plano, es buena conjetura de DONATUTI (*Contributi alla teoria del mandato*, II, Perugia, 1929, ps. 60 y ss.), y encuentra apoyo en la conexión que GAYO (III, 137) señala entre consensualidad y bilateralidad.

⁶⁴ Sobre el tema, cfr. en particular PARTSCH, *Studien zur Neg. gestio*, Heidelberg, 1913, ps. 54 y ss.; y LENEL, *Edictum*, 3ª ed., p. 254.

Fundándose, igual que la sociedad, sobre la confianza recíproca, el mandato se extingue, si no se ha iniciado la ejecución, con la revocación del mandante o con la renuncia del mandatario; en cambio, cuando la ejecución ha comenzado, uno está obligado a soportar los efectos y otro a llevarla a término. Por la misma razón, el mandato se extingue con la muerte de una u otra parte. Diverso fundamento tiene la regla que prohíbe el *mandatum post mortem*, es decir, el encargo contractual a cumplirse después de la muerte de una de las partes; razón de la prohibición es quizá la neta separación que los romanos establecen entre los contratos (cuya eficacia sólo casualmente se prorroga más allá de la muerte de los interesados) y el testamento, que regula la suerte de toda relación jurídica transmisible para después de la muerte⁶⁵.

§ 5. LOS PACTOS

En su más antiguo significado técnico, el sustantivo *pactum* expresa, como el antiguo verbo *pacere* y también el más moderno *pacisci*, un acuerdo concluido entre dos personas, de las cuales una está vinculada hacia la otra, con el fin de disolver o transformar el vínculo. Así, en las XII Tablas, a propósito de las lesiones graves y para aludir a la composición que puede evitar el talión, se decía *ni cum eo pacit*, y de *pacere* se hablaba también a propósito del ladrón que se redime; a estas disposiciones se vincula el principio clásico según el cual las acciones de injuria y de hurto se extinguen si tiene lugar un *pactum*. Es cierto que también en todo otro caso, en el régimen de las *legis actiones*, influyese sobre el proceso el acuerdo concluido entre las partes; pero nada sabemos sobre la estructura de los respectivos *pacta* y sobre los modos de su influencia.

Por derecho pretorio, la situación es bastante más clara. En efecto, una cláusula edictal, sobre cuyo contenido esencial se ha formado hoy entre los romanistas una *communis opinio*, prometía tener en cuenta los *pacta conventa*, siempre que no fuesen contrarios al derecho objetivo. El acuerdo que así quedaba protegido se llamó habitualmente *pactum de non petendo*, acuerdo entre

⁶⁵ Cfr. BONFANTE, *Mandatum post mortem*, en *Scritti giuridici varii*, III, ps. 262 y ss.; y *supra*, p. 335.

acreedor y deudor para que aquél no intentase contra éste la acción que le correspondía; después de haber prometido en su edicto prestar sanción a este acuerdo, el pretor concedía al deudor demandado una excepción (*exceptio pacti*), mediante la cual, aun sin poner en duda la existencia de la obligación deducida en juicio, se oponía a la respectiva acción la iniquidad del actor que no guardaba fe a la palabra empeñada, y se conseguía así la absolución⁶⁶.

Junto a este significado técnico, las palabras *pactum* y *pacisci* tenían otro en el lenguaje común, es decir, indicaban cualquier acuerdo no formal, contraído ya en ocasión del cumplimiento de un acto jurídico, ya después de él, ya independientemente. Inspirándose en esta tendencia del común discurso, los juristas acostumbraron también ellos a hablar de *pactum* para indicar el acuerdo puro y simple; la mayor parte de las veces en sentido negativo, es decir, para poner en relieve la ineptitud de las convenciones, o de las convenciones no revestidas de formas particulares, para producir ciertos efectos. Así, a propósito de la obligación de pagar los intereses, PAULO (*Sent.* 2, 14, 1) observa que *ex nudo pacto... actio non nascitur* (donde el *nudum pactum* está contrapuesto a la estipulación); mientras en la máxima que ya conocemos (p. 219), "*traditionibus et usucapionibus dominia rerum non nudis pactis transferentur*", la expresión *nuda pacta* abraza todos los contratos, comprendida la estipulación, en contraposición a los modos de adquisición de la propiedad.

Inspirándose siempre en la misma dirección del lenguaje común, los juristas dan a veces (pero menos a menudo de lo que nuestras fuentes alteradas harían considerar) el nombre de *pacta* a las cláusulas accesorias de los contratos: así, se llama *pactum de non praestanda evictione* al acuerdo entre vendedor y comprador para que éste no pretenda la garantía por evicción; *pactum de dolo non praestando* al acuerdo (nulo, como veremos en el cap. XVII) entre depositante y depositario para que éste no responda por la pérdida dolosa de la cosa. Acuerdos, todos éstos, que no tienen existencia autónoma, pero que se incorporan al contrato

⁶⁶ Cfr. MANENTI, *Contributo alla teoria generale dei pacta* (1891): de acuerdo con él, hasta este punto, BONFANTE, *Sui contractus e sui pacta* (*Scr. giur.*, 3, ps. 135 y ss.). Para la reducción al solo *pactum de non petendo*, cfr. PEROZZI, *Ist.*, 2^a ed., II, ps. 369 y ss.

mismo si se hallan incluidos en un contrato protegido por *bonae fidei iudicium* (*pacta in continenti*). En contraposición a éstos, se llaman *pacta ex intervallo* a los concluidos después del contrato y que en general sólo valen si son en favor del demandado.

Finalmente, hay también algún caso en que los nombres de *pactio* y *pactum* son atribuidos a negocios productivos de efectos jurídicos, pero fuera del campo de las obligaciones propiamente dichas. Así, se llamó *pactum hypothecae* (o. *conventio pignoris*) a la convención sobre cuya base se constituía un derecho real de garantía sin la entrega de la cosa (cfr. ps. 292 y ss.); y análogamente se llamó *pactio et stipulatio* (es decir, acuerdo confirmado por estipulación) a la convención usada para constituir sobre los fundos provinciales derechos análogos a las servidumbres (p. 273). La expresión sirvió para evitar el nombre de *contractus*, que habría aludido a obligaciones, mientras que la característica de los acuerdos en cuestión es la de constituir derechos reales.

Las excepciones analizadas no están desprovistas de coordinación porque el *pactum* es siempre en ellas antitético del *contractus*; el *pactum* es socialmente afín a éste, pero desde el punto de vista jurídico se le contrapone de diverso modo.

En el atormentado pensamiento científico de los bizantinos, esta figura ambigua ejerció una particular fascinación; trataron, por eso, de ambientarla definitivamente en el mundo jurídico, elaborándole toda una teoría. Es seguro que se deben a los bizantinos las definiciones que comprenden en el concepto de *pactum*, de otra manera llamado *conventio*, todos los contratos nominados e innominados, y además los acuerdos excluidos del ya amplio sistema contractual justiniano; a ello se debe, indudablemente, la minuciosa doctrina de los *pacta adiecta*, con sus distinciones en *pacta quae augent et quae minuunt contractum*; *quae gignunt o transformant o tollunt actionem*; *quae naturam contractus mutant vel ei insunt illam non mutantia*, campo verdaderamente ideal para la ejercitación de las mentes dispuestas a los juegos de paciencia del doctrinarismo⁶⁷.

⁶⁷ Para un amplio examen de la doctrina oriental contemporánea y posterior a JUSTINIANO, cfr. ROTONDI, *Scritti giuridici*, II, ps. 210 y ss. Para la crítica del *Corpus iuris*, en diverso sentido, BIONDI, *Iudicia bonae fidei*, ps. 22 y ss.; GROSSO, "Memorie Istit. Giur. Torino", sec. II, n° 3, 1928, y en el libro cit. *supra* (p. 326, n. 1), ps. 240 y ss.

Desde el punto de vista práctico, el derecho justiniano introduce nuevamente, bajo el nombre de *pactum dotis* y *pactum donationis*, promesas no formales aptas para alcanzar fines que en el derecho clásico sólo podían lograrse con la estipulación (o, en caso de dote, con la dictio: cfr. p. 358).

FRANJA
MORADA

CAPÍTULO XV

LAS OBLIGACIONES NO CONTRACTUALES DE ACTO LÍCITO

1. Legados *per damnationem* y *sinendi modo*. — 2. *Pollicitatio* y *votum*. —
3. La *negotiorum gestio* y las figuras afines. — 4. Tutela. — 5. La *indebiti solutio* y las otras hipótesis de *condictio* como acción de enriquecimiento. — 6. *Communio incidens*.

La justificación (negativa) de esta categoría, y las razones por las cuales renunciamos a la terminología justiniana del cuasi contrato, han sido ya señaladas con suficiente amplitud (ps. 327 y ss.). Bastará ahora examinar los tipos particulares.

1. El *legatum per damnationem* es una disposición testamentaria a título particular, con la cual se impone al heredero la obligación de transmitir alguna cosa u otra utilidad (perteneciente a la herencia, al heredero o a un tercero) a la persona designada por el testador. La antigua fórmula, de la cual toma el nombre, es *Titius heres meus Seio sestertium X milia damnas esto dare*; y en época más reciente, pudo ser sustituida por un simple *dato*. La diferencia con el legado *per vindicationem* (p. 219; cfr. p. 639) es palmaria: mientras éste hace titular del derecho al legatario, sin la mediación del heredero, de modo que aquél tiene la acción *in rem* contra quienquiera que posea la cosa, el legado *per damnationem* crea solamente una obligación para el heredero, atribuyendo al legatario una *actio in personam*. Acción que corresponde a la *condictio*, en las acostumbradas formas de la *actio certae creditae pecuniae* y de la *condictio certae rei*; salvo que en ella se agrega en la *intentio* la mención de la causa (por ejemplo: “*si pareret Nm. Nm. Ao. Ao. sestertium X milia ex testamento Lucii Titii dare oportere*”), de donde el nombre especial de *actio ex testamento*. La obligación nacida del legado *per damnationem* es, por

esto mismo, tan rígida como la que nace de la estipulación; y no hay que maravillarse si muchas veces los principios generales de las obligaciones son desarrollados por los romanos sobre la base de los dos paradigmas de la estipulación y del legado.

Estructura análoga a la del legado *per damnationem* tiene el *sinendi modo*, en virtud del cual se impone al heredero dejar que el legatario se apropie de un objeto perteneciente al patrimonio hereditario o al del mismo heredero (por ejemplo, *heres meus damnas esto sinere L. Titium hominem Stichum sumere sibi que habere*). El heredero está aquí obligado, por lo menos en los orígenes (cfr. GAYO, II, 214), no a un acto de transmisión sino a una simple tolerancia, es decir, a un *non facere*, que según la terminología analizada a propósito de la estipulación, es un *incertum* (cfr. p. 364); en consecuencia, al legatario le corresponde una *actio incerti, ex testamento*, tendiente al *quidquid heredem ex testamento dare facere oportet*¹.

Para cualquier otro detalle sobre los legados descritos, nos remitimos a la exposición sobre las sucesiones (cap. xxvi). Aquí interesa recordar solamente que para poder aproximar a los contratos la obligación del heredero, los romanos la hacen nacer de la aceptación de la herencia, y que en las *res cottidianae* posclásicas la misma *aditio* es considerada como el cuasi contrato del cual surge la obligación. Eliminada la ilusión de que todo hecho lícito productivo de obligación debe ser un contrato o tener sus apariencias, podemos volver a la concepción que se refleja en las fórmulas testamentarias, es decir, que fuente de la obligación sea la declaración unilateral del testador².

2. Otras declaraciones de voluntad unilateral, pero *inter vivos*, y emitidas por el deudor mismo, son la *pollicitatio* y el *votum*. La primera es una promesa hecha por un ciudadano a la ciudad con ocasión de la candidatura a una magistratura o sacerdocio o de la entrada en funciones, y que tiene por objeto una obra en pro-

¹ Naturalmente, también la acción derivada del legado *per damnationem* podría ser *incerti* a causa del objeto, si, por ejemplo, el legado fuese genérico o alternativo.

² No dejo de advertir que en varios pasajes, aun gayanos (III, 35), se dice que el heredero *se obliga* con la aceptación de la herencia; pero esta expresión no se refiere a las obligaciones que nacen del legado, sino a la asunción de las deudas que ya pesaban sobre el causante.

vecho de la ciudad misma; el *votum*, en cambio, es la promesa de una cosa a una divinidad, con fin propiciatorio o expiatorio. Está dicho expresamente en D. 50, 12, 2 § 1³, que el voto, cuando lo hace un *pater familias*, obliga; probablemente en la época clásica los sacerdotes de la divinidad destinataria pudieran hacer valer el compromiso por vía de *cognitio extra ordinem*. En cuanto a la *pollicitatio*, parece que para crear la obligación no basta la promesa, sino que debe tener lugar el comienzo de la obra; en el derecho justiniano, las condiciones conjuntivamente requeridas por el derecho clásico se disocian, en el sentido de que la promesa obliga por sí misma si se hace *ob honorem vel sacerdotium decretum decernendumve*, mientras que si se hace *sine causa* vincula solamente después del comienzo de la obra⁴. La tutela de la relación debió estar también aquí en la *cognitio extra ordinem*.

3. La *negotiorum gestio* es quizá el más típico y notable entre aquellos a que el derecho justiniano llama cuasi contratos. Consiste, como su nombre lo indica, en la actividad de quien, sin haber recibido mandato para ello, y eventualmente también en la ignorancia del interesado (*dominus negotii*), realiza negocios jurídicos o de cualquier otra manera cuida los intereses de otro. De tal actividad nace para el agente mismo la obligación de proseguirla hasta la conclusión del negocio, y para el interesado la de aceptar la gestión que haya conducido a resultados útiles, e indemnizar al gestor por los gastos y los daños sufridos.

Esta definición, que capta los rasgos más característicos de la institución en el derecho justiniano, no corresponde exactamente a su estructura originaria, sea que se considere, según la dirección dominante entre los estudiosos, que la única hipótesis prevista por el Edicto pretorio fuese la de la representación procesal y que la ulterior casuística se le haya agregado lentamente, sea que, dando directamente vuelta a la institución justiniana, se identifique para el derecho clásico la *negotiorum gestio* con la

³ Está quizá interpolada la frase que da fuerza obligatoria al *votum* hecho por el hijo de familia o por el esclavo con la *auctoritas patris dominive*.

⁴ Diversamente ASCOLI, *Il concetto della donazione*, etc., en "Studii e Documenti di Storia e Diritto", 14, p. 67; la opinión que expongo se acerca mucho a la tesis de ALBERTARIO, *La pollicitatio*, Milano, 1931.

procuración⁵; sea, en fin, que se piense, como me parece menos aventurado, que un régimen fijado por el derecho civil con relación al *procurator* haya sido extendido por el pretor al gestor voluntario. De cualquier manera que sea, el pretor concedió al gestor y al *dominus negotii* acciones *in factum*, con las cuales concurren, no sabemos bien si posteriores o nacidas en su origen para y contra el *procurator*, acciones *in ius ex fide bona*.

Es muy discutido si se requiere en el gestor, aparte de la efectiva incidencia del negocio por él gestionado en el patrimonio de otro, también un *animus aliena negotia gerendi*, es decir, si la acción *negotiorum gestorum* procede también cuando el gestor haya obrado en el común interés propio y de otro (como el condómino que hace gastos para la conservación de la cosa común; cfr. p. 257) o en la inteligencia de cuidar solamente el propio interés (como quien erróneamente se considere heredero). Las contradicciones entre los textos de la compilación han llevado a hipótesis opuestas: según una, el *animus aliena negotia gerendi* sería un requisito clásico que JUSTINIANO habría tendido a eliminar (RICCOBONO); para la otra, JUSTINIANO sería el inventor de este requisito, mientras que los clásicos se habrían limitado a exigir el hecho objetivo de la gestión (PARTSCH). No es éste el lugar de retomar la exégesis de los textos para establecer si las contradicciones son conciliables, en el sentido mismo de la jurisprudencia clásica; en el estado actual parece más en consonancia con la construcción tardía de la obligación *quasi ex contractu* la doctrina que funda la gestión sobre el conocimiento del carácter ajeno del negocio, mientras que el criterio de la gestión objetiva parece responder mejor al espíritu realista de la jurisprudencia antigua (cfr. p. 110).

No menos discutido es, en su aplicación práctica, el requisito de la utilidad. Es natural que encuentre aquí particular considera-

⁵ Aludo a la doctrina sostenida por FRESE en *Mélanges Cornil*, I, ps. 325 y ss., y en *Studi Bonfante*, 4, ps. 397 y ss. (sobre la cual cfr. mi *Responsab. contr.*, 2ª ed., ps. 205 y ss.). Sobre las otras cuestiones señaladas a continuación, cfr. en especial WŁASSAK, *Zur Geschichte der "negotiorum gestio"* [Sobre la historia de la "negotiorum gestio"], Jena, 1879; PACCHIONI, *Trattato della gestione degli affari altrui*, Lanciano, 1893; PETERS, *Generelle und spezielle Aktionen* [Acciones generales y especiales], en la "Rev. Fundac. Savigny", 32, 1911, ps. 263 y ss.; PARTSCH, *Studien zur "negotiorum gestio"* [Estudios sobre la "negotiorum gestio"], I, en *mis Rendiconti Accademia Heidelberg*, 1913; RICCOBONO, *Dal dir. rom. class.*, etc., espec. en las ps. 170 y ss.; BIONDI, *Iudiciae bonae fidei*, I, ps. 73 y ss.; KRELLER, *Festschr. Koschaker*, II, ps. 193 y ss.

ción la apreciación individual del *dominus*, en cuanto fuese precedentemente conocida por el agente (así, la adquisición de esclavos o la locación de un fundo hecha por mí para otro, podrá tener para el *dominus* eficacia obligatoria solamente si me constaba su intención de comprar o de alquilar); fuera de este criterio, el *dominus* no puede ser vinculado sino por actos de gestión que respondan, según la común apreciación, a una utilidad objetiva, y por el contrario, no puede en semejantes casos oponer su particular intención, desconocida al gestor y aberrante (como la de quien quisiera dejar caer la casa antes que hacer en ella las reparaciones necesarias). Sólo en este orden de ideas se puede comprender por qué algunos textos conceden, si no la acción *negotiorum gestorum*, una acción análoga (*utilis*) también a quien gestiona *prohibente domino*.

La *negotiorum gestio* puede estar limitada a un negocio determinado, pero puede referirse también (y tal era su fin originario si se identificaba con la procuración) a todos los negocios de una persona, o a todos los que ésta tiene en una ciudad o provincia determinada. En estos últimos, es obligación del gestor no omitir ningún acto de los comprendidos en la esfera de acción que ha asumido; al respecto, la jurisprudencia atribuye particular relieve a la obligación de exigir, conjuntamente con los créditos contra terceros, también los que existan contra él mismo (a *semetipso exigere*), con el efecto de que con la acción *negotiorum gestio* puedan hacerse valer las obligaciones que por cualquier causa pre-existían entre gestor y principal.

Bajo el concepto de *negotiorum gestio* se comprenden también administraciones legales de patrimonios, como ocurre con las diversas hipótesis de curatela (*furiosi*, *prodigi*, y —por lo menos por derecho justinianeo— *minoris*). Pero frente a la regla general de que el gestor se ocupa de los negocios ajenos “*sua sponte et nulla necessitate cogente*”, no corresponden, por lo menos en las dos primeras hipótesis, las acciones normales *negotiorum gestorum*, sino acciones adoptadas a su imitación (*utiles*: cfr. cap. xxiv, § 3).

Una forma particular de gestión a la que el pretor proveyó de acción especial se da cuando alguien, impulsado no por meras razones de piedad sino por el deseo de sustituir dignamente a la persona a quien incumbiría la obligación, se encarga de un funeral. La *actio funeraria* compete, en la medida de los gastos conforme a la posición social del difunto, contra aquel *ad quem funus*

pertinet, es decir, en primer lugar contra la persona a quien el difunto mismo hubiera designado a este fin en el testamento, en segundo lugar contra el heredero, el *bonorum possessor*, el padre a quien haya correspondido el *peculio castrense* del hijo, etc.⁶

4. Una administración de negocios ajenos se puede tener también en la *tutela impuberis*⁷. Obligaciones análogas a las de la *negotiorum gestio* surgen, sin embargo, en derecho clásico, como se verá en el cap. XXIV (§ 1), solamente cuando la tutela es dativa, es decir, cuando el tutor es designado por el magistrado; mientras que respecto del tutor legítimo y del testamentario los remedios correspondientes al pupilo se adaptaban en los orígenes a su calidad de titulares fiduciarios del patrimonio. La acción concedida al tutor y contra el tutor dativo, cuya fórmula indicaba expresamente el cargo, fué llamada *actio tutelae*. En el derecho justiniano, el remedio es ejercible en contra y en favor de cualquier tutor, y también la tutela se considera un cuasi contrato.

5. En la conocida lista de los cuasi contratos, también ocupa un puesto la *indebiti solutio*; es más: se ha visto (p. 327) que precisamente a propósito de ella, GAYO (III, 91) dirigía la primera crítica contra la vieja clasificación de las fuentes de las obligaciones.

Se tiene una *indebiti solutio* cuando alguien, creyendo estar vinculado por una obligación de dar, trasmite al presunto acreedor una suma de dinero u otra cosa cualquiera; puesto que la propiedad ha pasado al *accipiens*, el descubrimiento del error no podría legitimar el ejercicio de la *rei vindicatio*; pero al *solvens* se le concede, para hacerse retransmitir las cosas dadas, la acción *in personam* típica, la *condictio*, que en esta aplicación particular toma el nombre de *condictio indebiti*. Presupuesto esencial para la procedencia de la acción es el error de quien paga y de quien recibe el pago; si el que paga supiese que no está obligado, la dación sería irrepetible por cuanto se consideraría donación; si el que recibe el pago supiese que nada se le debe, cometería un hurto, de manera que la *condictio* correspondería en su contra *ex causa furtiva*⁸.

⁶ Sobre los diversos puntos cfr. los estudios de DE FRANCISCI, en "Il Filangieri", 40, 1915; "Rend. Ist. Lomb.", 48, 1915; "Annali Facoltà Giur. Perugia", 31, 1920; y DONATUTI, "Stud. e Docum.", 8, 1942, ps. 48 y ss.

⁷ Pero no en la *tutela mulierum*; cfr. cap. XXIV, § 2.

⁸ De otra manera SOLAZZI, *L'errore nella "condictio indebiti"*, en "Atti Accad. Napoli", 59, 1938, ps. 291 y ss.; y en otros escritos.

Hay casos, por lo demás, en los cuales el pago hecho por error no da lugar a repetición (*soluti retentio*): son los de las llamadas obligaciones naturales (cap. XIX, § 1).

Con el mismo fundamento, en la categoría del cuasi contrato la dogmática posclásica habría podido incluir varios otros casos de *condictio*. Se ha señalado ya varias veces que esta acción tiende, sobre todo, a la restitución de cosas que sin razón justificativa han pasado de la propiedad de una persona a la de otra; la obligación así tutelada, y que sólo en caso de mutuo se refiere a un contrato, podría considerarse derivada de cuasi contrato en todas las hipótesis. Entre ellas deben recordarse:

a) el caso, ya examinado a propósito de los contratos inno-
minados (ps. 353 y ss.), de la *condictio ob rem dati re non secuta*;

b) el caso de la *condictio ob turpem vel iniustam causam*, que tiene lugar cuando se ha dado alguna cosa para que otro cumpla, o también para que no cumpla, actos contrarios a la moral o al derecho; aquí la *condictio* procede sólo cuando no ha habido torpeza más que por parte del *accipiens*, no ya si la hubo también por parte del *tradens* o de ambos (*in pari causa turpitudinis melior est condictio possidentis*);

c) el caso de la *condictio sine causa*, que ocurre cuando se ha dado una cosa para un fin que de hecho no se realiza; por ejemplo, si he dado a alguien objetos preciosos ante el temor de una muerte inminente (*donatio mortis causa*) y el peligro ha pasado, o si los he dado para dotar a una joven y el matrimonio ha fracasado.

Por último, corresponde recordar, aunque anormal, la característica, *condictio ex causa furtiva*, concedida a la víctima del hurto contra el ladrón y sus herederos; anormal porque aquí la *condictio* tiene por fuente un acto ilícito, y sobre todo porque encuentra aplicación aun no habiéndose operado, por lo menos normalmente, un pasaje de propiedad⁹.

6. En la categoría de los cuasi contratos se suele incluir, sobre las huellas de las Instituciones justinianeas (3, 27, 3 y ss.), la *communio incidens*, es decir, el condominio procedente de cualquier

⁹ Cuidese no confundir esta acción, que tiende a la restitución de la cosa, con la acción penal de hurto, de la cual hablaremos en las ps. 412 y ss. La *condictio ex causa furtiva* es quizá la única "acción civil (es decir, patrimonial) que nace de delito", conforme a nuestro concepto del delito civil, que sea conocida al derecho romano.

fuente que no sea el contrato de sociedad; y esto en relación con aquella división de los gastos y de las utilidades de la cosa común, que hemos visto (p. 257) tenía lugar en los juicios *communi dividundo* y *familiae erciscundae*. La construcción de este tipo de *obligatio* se vincula con el relieve que el derecho justiniano da a las llamadas *praestationes*, mientras el derecho clásico hacía nacer las diversas obligaciones de resarcimiento o de indemnización de los actos particulares de gestión¹⁰.

FRANJA
MORADA

¹⁰ Contra la clasicidad de la *societas re contracta*, en la que el condominio sería considerado un contrato, cfr. p. 389, n. 60.

CAPÍTULO XVI

LAS OBLIGACIONES NACIDAS DE ACTO ILÍCITO

§ 1. EL DELITO Y LA ACCIÓN QUE NACE DEL DELITO

En el estudio de la obligación nacida de delito es más que nunca necesario sustraerse a la sugestión de las ideas modernas.

Consideramos al delito, en sentido propio, como violación de una norma establecida en interés colectivo; por lo tanto, la idea de delito es para nosotros inseparable de la de la acción pública, intentada en nombre del Estado por un funcionario especial (ministerio público)¹, y de la pena pública, consista ella en una restricción de la libertad personal del delincuente o en una multa o suma a entregar al Estado. En las relaciones entre particular y particular, entre ofensor y ofendido, el concepto de pena no encuentra lugar; obsta a ello la absoluta eliminación, por la ley y la costumbre, de todo vestigio de la venganza primitiva. En consecuencia, entre particulares el hecho ilícito o delito civil (coincida o no, en los casos concretos, con el delito penal) no se toma en consideración sino por el desequilibrio que eventualmente causa en los patrimonios: "cualquier hecho doloso o culposo que ocasiona a otro un daño injusto, obliga al que ha cometido el hecho a *resarcir el daño*" (art. 2043, Cód. Civ. it.). Por consiguiente, mientras la acción pública no podría dirigirse contra los herederos del cul-

¹ Sólo impropriamente —como todos saben— ciertos delitos (por ej., apropiación indebida, injuria y difamación, adulterio) se llaman "de acción privada"; es verdad que en ellos la acción no puede intentarse sin la querrela del interesado, pero la acción misma, es decir, el requerimiento de la pena, corresponde al ministerio público. [Adviértase que el autor hace aquí referencia al derecho italiano; en el argentino, los delitos de acción privada son el adulterio, las calumnias e injurias, la violación de secretos y la competencia desleal].

pable, respecto a los cuales no tiene lugar la exigencia de defensa social en que se inspira la pena, la acción correspondiente al ofendido por resarcimiento del daño, procede también contra los herederos del ofensor, como toda otra acción civil.

El derecho romano, en cambio, divide los actos que la conciencia social estima merecedores de pena en dos vastas categorías: los delitos públicos, más propiamente *crimina*, y los delitos privados, para los cuales más técnicamente se usan las denominaciones de *delictum* y de *maleficium*. El delito público, verdadera infracción del orden social que ataca a toda la *civitas* (por ejemplo, la traición y el parricidio), da lugar a una persecución pública, realizada primero en los comicios populares y después ante los jurados llamados *quaestiones perpetuae*, que remata en una *poena publica* (muerte, *interdictio aquae et ignis*, multa a pagar al erario, etc.); en cambio, el delito privado, como el hurto, el daño, la lesión personal, se siente como ofensa al individuo y legitima una reacción individual. Ésta, en tiempos prehistóricos, es ilimitada, es decir, libre e incontrolada venganza, y sucesivamente se va proporcionando a la ofensa en el régimen del talión; en fin, a través del uso de las composiciones, primero convencionales y después legales, se reduce a los límites de una pena pecuniaria, infligida por el juez como consecuencia de la acción intentada por el ofendido (cfr. p. 319). Pero es siempre pena, es decir, por parte del ofensor, una expiación, y por parte del ofendido, la satisfacción de una venganza: su presupuesto es la ofensa hecha a la víctima y no ya el desequilibrio patrimonial; es más: si hay desequilibrio, éste es, por lo común, reparado con otros medios.

La *obligatio ex delicto* es, por lo tanto, la obligación estrictamente personal que vincula al ofensor respecto del ofendido, constriniéndolo a sufrir la pena pecuniaria.

Refiriéndose el concepto y la terminología clásica de la *obligatio*, como sabemos, al *ius civile*, la *obligatio ex delicto* surgía solamente de los cuatro delitos típicos: del *furtum*, de la *rapina* (*bona vi rapta*), de la *iniuria* y del *damnum iniuria datum*, conocidos el primero y la tercera ya por la costumbre antiquísima, y reprimidos ambos por las XII Tablas; previsto y reprimido el cuarto por una ley comicial muy antigua (*lex Aquilia*), considerada originariamente la segunda como un caso de hurto, mientras el pretor no proveyó con una acción especial. Los numerosos actos que el pretor por primera vez persiguió como ilícitos, reprimiéndolos,

dolos —según lo acostumbrado— con acciones *in factum*, no crean obligaciones; los posclásicos han elegido entre ellos —como sabemos— un pequeño grupo para constituir con él sus obligaciones *quasi ex delicto*².

Tanto a las obligaciones *ex delicto* como a las obligaciones pretorias análogas corresponden las acciones penales; ellas tienden a la aplicación de una pena, pero se ejercen en las formas del proceso privado (cfr. p. 121). De su función derivan ciertas características generales³:

1) La *noxalidad*. Se llaman *noxales* (de *noxa*, que según la interpretación dominante equivale a delito) las acciones penales intentadas contra el padre de familia o el amo por el delito privado del hijo o del esclavo⁴. En este caso, la acción no se intenta pura y simplemente, sino *cum noxae deditio*, es decir, con una cláusula que permite al demandado liberarse de toda responsabilidad abandonando el delincuente al ofendido; cuando no quiera consentir en la *noxae deditio*, el padre o amo sufre la pena pecuniaria. El régimen, que para los delitos del esclavo permanece en vigor hasta JUSTINIANO, en lo que respecta a los delitos del hijo de familia encontró, en cambio, límites considerables; ya en la época clásica se admitía que el hijo, para evitar el peligro de la *noxae deditio*, pudiese defenderse por sí cuando el padre descuidase la defensa; y más tarde, cuando el régimen de los peculios y de los bienes adventicios hubo puesto también al *filius familias* al frente de un patrimonio, la razón de la acción noxal desapareció; JUSTINIANO la abolió, estableciendo que se pudiese en todo caso obrar contra el hijo de familia delincuente.

Para que se tenga acción noxal es necesario que quien ejerce la potestad no haya tenido noticia previa del delito o posibilidad

² Cfr. ps. 320, 328 y ss., y los autores citados en la p. 315, nota 1. La demostración de que también la voz *delictum* esté reservada a las infracciones castigadas por el *ius civile* la intenta ALBERTARIO, *Delictum e crimen*, Milano, 1924 (= *St. di dir. rom.*, III, ps. 141 y ss.); pero aquí el rigor terminológico es aun menor que para la voz *obligatio* (cfr. p. 321, nota 3).

³ Cómo ellos se refieran todos al concepto ya señalado de la *personalidad* de la pena, está muy bien subrayado por BRANCA, *op. cit.*, en la p. 247, nota 47 (espec. p. 186).

⁴ Sobre la tendencia justinianeana a extender el principio de la *noxalidad* fuera del campo de los delitos privados (a casos de responsabilidad contractual o a *crimina publica*), cfr. BIONDI, *Actiones noxales*, Palermo, 1925, ps. 42 y ss., y sobre toda la materia véase ahora DE VISSCHER, *Le régime romain de la noxalité*, Bruxelles, 1947.

de impedirlo; en la hipótesis del *pater familias* conocedor del hecho, la acción se intenta *sine noxae deditione*, y el *pater* soporta irremisiblemente la pena.

La responsabilidad noxal pesa sobre el *pater* por la imposibilidad de hacerla recaer directamente sobre seres que no tienen capacidad jurídica patrimonial propia; pero, puesto que por razón natural la responsabilidad es del delincuente mismo, vale el principio de que *noxæ caput sequitur*, el que hace que responda no quien tenía bajo potestad al culpable en el momento del delito sino quien lo tiene en el momento en que se intenta la acción, y que, en fin, ésta pueda intentarse (naturalmente que no más como *noxalis*) también contra el hijo que ha salido de la potestad o contra el esclavo manumitido. Con respecto a los esclavos, la *noxæ deditio* se lleva a la práctica mediante el abandono y la correlativa toma de posesión; parece, en cambio, que el hijo de familia culpable fuese objeto de *mancipatio* y cayese en aquella posición de cuasi esclavitud que se llama *causa mancipii* (cap. XXIII, § 4).

Análoga a las acciones noxales es, por lo menos en la concepción primitiva, la *actio de pauperie*, correspondiente contra el dueño de un animal doméstico que por ser indómito o por otra causa que le sea propia ha provocado daño a otro⁵. También aquí el dueño puede evitar la condena entregando el animal, residuo histórico de una época en que la venganza se ejercía también contra los seres privados de razón.

2) La *intransmisibilidad*. Puede considerarse probable que la venganza primitiva ha sido familiar y no individual, y, eventualmente —para aquella parte de la población romana (el patriciado) que se organizaba en *gentes*—, gentilicia. Pero en la época de que tenemos precisas noticias históricas, el criterio de la venganza, trasformada en *poena pecuniaria* objeto de *obligatio ex delicto*, vale sólo entre ofensor y ofendido. La acción penal era, pues, en el comienzo de la República, *intransmisibile activa y pasivamente*, es

⁵ Si el daño fuese causado por animal no doméstico, la acción de *pauperie* no procedería, pero el dueño respondería eventualmente en nombre propio de los daños procedentes de la inobservancia del edicto edilicio de *feris*; si fuese causado por culpa del patrón o de terceros (como en el caso de la acción de *pastu pecoris*), respondería el culpable, o eventualmente, tratándose de un esclavo o hijo de familia, se intentaría contra el *pater* la acción noxal.

decir, que no correspondía ni a los herederos del ofendido ni contra los herederos del ofensor. Pero la intrasmisibilidad activa, contrariada de todo modo por la jurisprudencia, se trasformó bien pronto en la regla especial de unas pocas acciones, civiles y pretorias, en las cuales se presentaba más genuina la función de venganza (las llamadas *actiones vindictam spirantes*), primeras entre todas las acciones de injuria y de sepulcro violado.

Mucho más tenaz es el principio de la intrasmisibilidad pasiva, que no solo permanece intacto durante todo el período clásico, sino que ni siquiera en la época justiniana es explícitamente abandonado. Solamente se admite, en varios textos de las Pandectas, que aun extinguiéndose con la muerte del ofensor la acción penal, deba, sin embargo, otorgarse en su lugar, contra el heredero, una acción limitada a la ventaja patrimonial que él haya obtenido del acto ilícito (*in id quod ad eum pervenit*); en qué medida las disposiciones de este género pertenezcan al pretor y a la jurisprudencia clásica, en cuál se deban a los compiladores de JUSTINIANO, es todavía objeto de viva discusión⁶.

3. La *acumulabilidad*, que a su vez comprende dos diversas máximas: una, que si son varios los autores de un mismo delito, cada uno está obligado a sufrir la totalidad de la pena (véase más adelante, ps. 470 y ss.); otra, que el ejercicio de una acción penal no impide el de otras acciones destinadas a la recuperación de la cosa perdida, o, en todo caso, al resarcimiento del daño patrimonial (cfr. ps. 179 y 414). Máximas —como se ha visto y se verá (p. 470)— en buena parte abandonadas por el derecho justiniano.

4) Se observa, en fin, que mientras las acciones penales del derecho civil (*furti, iniuriarum, damni iniuriae*) son perpetuas, es decir que pueden intentarse sin límite de tiempo, las del derecho pretorio son anuales, esto es, corresponden dentro del año del hecho, o desde el momento en que el ofendido está en condiciones de intentarlas. También aquí la acción se encuentra frecuentemen-

⁶ Sobre el tema cfr. especialmente DE FRANCISCI, *Studii sopra le az. pen. e la loro intrasmissibilità passiva*, Milano, 1912; ALBERTARIO, *Note sulle az. pen., etc.*, en "Bull. Ist. Dir. Rom.", 26, 1913, ps. 90 y ss. (= *Studi di dir. rom.*, 4, ps. 369 y ss.); LEVY, *Privatstrafe und Schadensersatz im klass. röm. Recht* [Pena privada y resarcimiento de daños en el derecho romano clásico], Berlín, 1915; ROTONDI, *Scritti giuridici*, II, ps. 124 y ss., y 294 y ss.; RABEL, *Grundzüge*, ps. 456 y ss.; BESELER, *Contributi*, 4, ps. 258 y ss.; MAIER, *Prätorische Bereicherungsklagen* [Acciones pretorias de enriquecimiento], Berlín, 1932.

te otorgada más allá del año *in id quod pervenit*, o sustituida por una *actio in factum*; remedios de dudosa genuinidad.

La acción penal así descrita es opuesta por los clásicos (y especialmente en una célebre *definitio* de CASSIO LONGINO, D. 44, 7, 35) a la acción que tiende a obtener la restitución de una cosa o el resarcimiento de un daño (acción reipersecutoria). La distinción es clarísima cuando, cometiéndose el delito con la sustracción de una cosa, el ofendido dispone de la acción penal (para perseguir la pena) y de la acción reipersecutoria (para perseguir la cosa); ejemplo clásico es el de la concurrencia acumulativa entre la *actio furti*, por una parte, y la *condictio ex causa furtiva* o la *rei vindicatio*, por la otra. En otros casos, como en materia de injurias, la procedencia exclusiva de la acción penal no causa impresión, por cuanto falta un daño patrimonial á resarcir. Pero a veces, aun habiéndose producido un daño patrimonial, la acción penal es el único remedio de que la víctima dispone: esto ocurre, en particular, en el caso de la *actio legis Aquiliae*, es decir, en materia de daño. Frente a casos semejantes, la jurisprudencia clásica es algo incierta; las consecuencias de la penalidad (intrasmisibilidad, noxalidad, etc.) están fuera de cuestión, pero una tendencia doctrinal bien acogida por GAYO (iv, 8 y 9) niega que una acción sea estrictamente penal, si la víctima no dispone de otra acción de carácter reipersecutorio. Así, en materia de *actio legis Aquiliae*, aprovechando del hecho de que la acción se concede *in simplum* si el delincuente confiesa e *in duplum* si niega, GAYO afirma que en este segundo caso se persiguen *rem et poenam*, en el sentido de que una de las dos *aestimationes* de la cosa sirva para resarcir el daño, en tanto que la otra para castigar al culpable⁷.

⁷ Debe observarse que en el pasaje citado GAYO no habla sólo de la *actio legis Aquiliae*, sino que la menciona al lado de otras que tienen el mismo régimen procesal, e indudablemente reipersecutorias si intentadas *in simplum* (como la *actio iudicati* [cfr. p. 157], y la *actio ex testamento* [cfr. p. 397]); el régimen es, en efecto, propio de todas las acciones que en el origen se hacían valer con la *manus iniectio*, y tiene su fundamento en la duplicación con que se castigaba, en caso de sucumbir, al *vindex* o al deudor mismo *qui manum sibi depellebat* (cfr. p. 129). Esto sentado, la inclusión de la *actio legis Aquiliae* entre aquellas con las cuales "*rem et poenam persequimur*" podría parecer un error, provocado por la atracción de las otras. Pero no lo es; de otra manera, no se habría discutido, como GAYO nos informa en el § 8, el carácter penal de la *actio vi bonorum raptorum*. No me parece concluyente el modo como intenta liberarse de estos testimonios Voet, *Resarcimiento e pena priv.*, ps. 94 y ss.

Admisión verdaderamente peligrosa, que altera el concepto de la acción penal, y que, precisamente por eso, ha tenido un éxito enorme entre los compiladores justinianos (cfr., en especial, *Inst.*, 4, 6, 16 y ss.). En el sistema de la compilación, la acción de la ley Aquilia y otras análogas son mixtas, en parte penales y en parte reipersecutorias; penas no solamente en la duplicación que la condena sufre a cargo de quien niega el hecho, sino también en todo lo que, aun en el modo de calcular la condena *in simplum*, supera el valor de la cosa en el momento del delito.

§ 2. LOS CUATRO DELITOS PRIVADOS DEL "IUS CIVILE"

1. Parece que el concepto de *hurto*⁸ hubiera tenido, durante la época republicana, todo un desarrollo en virtud del cual, de una concepción estrictamente materialista (que corresponde aproximadamente a la moderna, de sacar una cosa mueble ajena del lugar donde está), se pasa a todos los casos en que se hace uso o de cualquier manera se echa mano a la cosa ajena mueble o inmueble. GAYO (III, 15): "*furtum autem fit non solum cum quis intercipiendi causa rem alienam amovet, sed generaliter cum quis rem alienam invito domino contrectat*", donde precisamente el verbo *amovet* alude al hecho de llevar la cosa del lugar en que se halla, mientras el *contrectat* abraza cualquier uso o ingerencia no consentida por el interesado. Por eso se admite el hurto no sólo de muebles sino también de inmuebles; no sólo de cosa que se hallaba en poder de otro sino también de la que estaba ya en poder del ladrón (apropiación indebida).

Tampoco la expresión *invito domino* debe entenderse en sentido absoluto; se comete hurto también de la cosa propia, si se la saca al acreedor *pignoratitio* o al poseedor de buena fe. Además, no es necesario que el ladrón quiera apropiarse de la cosa o ena-

⁸ Desgraciadamente ha quedado inconclusa, por la muerte prematura del autor, la obra de HUVELIN, *Études sur le furtum dans le très ancien droit romain*, cuyo primer volumen (Lyon-Paris, 1915) contiene la selección y el examen externo de las fuentes. Lo que HUVELIN ha demostrado, en un estudio breve y jugoso ("Rev. Hist. de Dr.", 1918, ps. 73 y ss.) es el origen justiniano del *animus lucri faciendi* como elemento esencial del hurto. Para el derecho clásico y justiniano son fundamentales las investigaciones de PAMPALONI, *Studii sul delitto di furto*, Torino, 1900-1901.

jenarla en propio provecho; al lado del *furtum rei*, mediante el cual esto se verifica, está el *furtum usus*, consistente en usar una cosa sin el consentimiento de quien tiene derecho a oponerse o fuera de los límites consentidos (cfr., por ejemplo, en las ps. 346 y 351, para el depositario y el comodatario).

Elementos constitutivos son: desde el punto de vista material, la ilícita ingerencia en la cosa; desde el punto de vista intencional, el conocimiento de la voluntad contraria del derecho-habiente (*dolus malus*); en fin, la correspondencia de este conocimiento con la verdad (exclusión del llamado delito putativo: cfr. GAYO, III, 198).

El derecho de las XII Tablas distingue entre el ladrón flagrante (*manifestus*) y el no flagrante (*nec manifestus*). Contra el primero, es decir contra el ladrón de quien la víctima del hurto llega a apoderarse sorprendiéndolo en el hecho, se producen inmediatamente las consecuencias habituales de la *manus iniectio*; la pena a pagarse para el rescate era el doble del valor de la cosa hurtada, que en caso de oposición (cfr. p. 129) se elevaba al cuádruple. Había también casos en que el ladrón flagrante podía ser muerto inmediatamente; es lo que ocurría si se lo sorprendía de noche, o si se defendía a mano armada, o si era un esclavo. Al ladrón no flagrante, en cambio, la pena del *duplum* se le aplicaba por medio de la *legis actio sacramenti* (cfr. p. 131). Al *furtum manifestum* se asimilaron, en los orígenes, tres hipótesis: el *furtum conceptum*, que tenía lugar cuando la víctima del hurto encontraba la cosa en poder de alguien como consecuencia de una pesquisa solemne (a hacerse, para evitar subterfugios, *lance licioque*); el *furtum prohibitum*, que se efectuaba cuando el sospechoso se rehusaba a tal pesquisa; y el *furtum oblatum*, que existía cuando el verdadero ladrón había ocultado la cosa poniéndola en poder de otro y éste hubiera estado expuesto a la venganza del hurtado. Pero para el primero y tercer caso, las XII Tablas habían establecido ya la pena del *tripulum*⁹.

En el derecho más evolucionado continúa considerándose lícita la muerte del ladrón nocturno o del que se defiende a mano

⁹ Cfr. sobre toda esta materia, aparte de la obra de HUVELIN, los estudios de DE VISSCHER, hoy reunidos en *Études de droit romain*, París, 1931, ps. 135 y ss., 215 y ss.; y ARANGIO-RUIZ, *La répression du vol flagrant et du non flagrant*, en la revista egipcia "Al Qanun wal Iqtisad", 2, 1932, ps. 109 y ss. (= *Rariora*, Roma, 1946, ps. 197 y ss.). Por último véase, desde el punto de vista comparatístico, los *Studies in Biblical Law* de DAUBE, Cambridge, 1947, ps. 201 y ss.

armada¹⁰; pero en cualquier otra hipótesis se aplica la pena pecuniaria impuesta por medio de la *actio furti*, salvo la *noxae deditio* para el caso de que el autor del hurto sea un sujeto a potestad. Para el hurto manifiesto la *actio furti* se intenta *in quadruplum*, lo mismo que para el *prohibitum*; para los otros casos subsiste el *duplum* o *triplum* ya fijado por las XII Tablas. El ya complejo sistema de las acciones de hurto es, además, integrado por el pretor con muchas acciones particulares, otorgadas para casos a los cuales las acciones normales no podían aplicarse por razones formularias: tales los contemplados bajo las rúbricas "de tigno iuncto" (para el poste o la viga ajena empleados para el sostén de una vid o en la construcción de un edificio, cfr. p. 214), "furti adversus nautas caupones stabularios", "si familia furtum fecisse dicitur", etc.¹¹.

La *actio furti* compete, contra el ladrón, a aquel "cuius interest rem salvam esse", y, en consecuencia, al propietario solamente si y en cuanto sea el principal interesado. Pero si, por ejemplo, la cosa hurtada ha sido dada en prenda, la acción de hurto compete al acreedor pignoraticio, por aquel mismo interés preponderante en la conservación de la cosa que hace atribuirle la posesión (cfr. p. 303); cuando la cosa ha sido, pues, objeto de uno de aquellos contratos como consecuencia de los cuales el consignatario es responsable de *custodia* (cfr. ps. 427 y ss.), como en los casos del comodatario, del lavandero o del remendón, la acción pertenece a éstos con preferencia al dueño¹².

¹⁰ Que en D. 48, 8, 9, sea justiniana la restricción del derecho de matar en los límites de la legítima defensa, fué visto por KARLOWA, *St. dir. rom.*, II, p. 776, n. 2.

¹¹ No es éste el lugar de examinar las hipótesis en las cuales, por disposiciones que pertenecen casi exclusivamente a la época imperial, el hurto (calificado) se considera delito público. Tal el abigeato (hurto de animales de pasto o establo), el hurto con efracción o escalamiento, el saqueo, el hurto balneario, la *expilatio hereditatis* (cfr., sobre las diversas hipótesis, FERRINI, *Diritto penale rom.*, en la *Encicl. del dir. pen.*, de PESSINA, I, ps. 224 y ss.). Estamos poco informados sobre el punto de si y en cuáles casos la acción privada impedía el ejercicio de la pública, o viceversa; pero indudablemente el predominio que la acción pública adquiere, especialmente en la época justiniana, es indicio de decadencia de la clásica *obligatio ex delicto*.

¹² Cfr. especialmente SCHULZ, *Die Aktivlegitimation zur "actio furti"* [La legitimación activa en la "actio furti"], en "Rev. Fundac. Savigny", 32, 1911, ps. 23 y ss.; BESELER, *Contributi*, 3, ps. 190 y ss.

Se ha señalado ya varias veces cómo concurren con la acción penal descrita las reipersecutorias y, sobre todo, la *rei vindicatio* y la *condictio ex causa furtiva* (ps. 179 y ss., 403).

2. Antes que un delito por sí, la *rapina* (*bona vi rapta*) es un caso de hurto; y precisamente de este carácter deriva su inclusión entre los delitos productores de *obligatio*. Pero en el año 66 a. C. el pretor LUCULLO publicó un edicto con el cual creaba una *actio in quadruplum* contra quien saquease bienes ajenos "*hominibus armatis coactisve*", es decir, con bandas armadas o con una multitud aunque desarmada. El edicto se refería, como es claro, a fenómenos de pillaje revolucionario, pero representó, sin embargo, un primer paso para la construcción del delito especial de robo; no es fácil decidir si ha sido la jurisprudencia la que extendió a la violencia ejercida por uno solo la disposición edictal sobre los "*homines armati coactisve*", o si, como parece más probable, un ulterior edicto de *bonis vi raptis* siguió al de LUCULLO. Lo que hay de cierto es que también aquí se da una acción *in quadruplum*, que como todas las acciones penales pretorias es anual, y parece que comprendiese originariamente también el valor de la cosa, perseguible éste aun después del año con una acción *in factum*; por eso algunos juristas del siglo I recordados por GAYO (IV, 8), consideraban a la acción en parte penal y en parte reipersecutoria. Aunque en el derecho clásico haya prevalecido, especialmente por obra de JULIANO, la opinión de que contra el autor de la *rapina* correspondiesen las mismas acciones reipersecutorias que competían contra el del hurto, y por eso GAYO parezca inclinado a considerar la *actio vi bonorum raptorum* como penal, JUSTINIANO refirma su naturaleza mixta.

Al robo, remoción violenta de cosas muebles, está equiparada la usurpación de bienes cometida con ocasión de un incendio,

Quizá por un residuo del sistema que no admitía matrimonio *sin manus*, es decir, sin que la mujer pasase bajo la potestad del marido (cfr. cap. XXI), el derecho clásico excluye, por lo menos normalmente, que al marido corresponda la *actio furti* contra la mujer, y sustituye a esta acción una especial *actio rerum amotarum*, también penal. Sobre esta base JUSTINIANO construye el nuevo principio de la *reverentia* entre cónyuges, y la relativa prohibición de las acciones infamantes. Cfr., sobre el particular, ZANZUCCHI, "Riv. Ital. Sc. Giur.", 42, 1906, ps. 3 y ss.; 47, 1910, ps. 3 y ss., 237 y ss.

terremoto, naufragio, asalto de piratas, hipótesis contemplada por una especial cláusula edictal¹³.

La circunstancia de estar el robo comprendido en el amplio concepto del hurto, hace que las acciones especiales concurren con la *actio furti* (*nec manifesti*)¹⁴. En D. 47, 2, 89 (88), y 47, 8, 1, se dice claramente que después de ejercida la acción de robo el magistrado debe negar la de hurto. En cambio, si ésta se intentase antes, parece que se podía hacerla seguir por la de robo; pero frente a la indudable manipulación de los textos, es incierto si los clásicos dieron la segunda acción en la acostumbrada medida del cuádruple (FERRINI), o por el simple valor de la cosa, en sustitución de la acción reipersecutoria (BETTI), o por el doble que era la diferencia entre la pena aplicable por la acción en cuestión y la ya conseguida con la *actio furti*; quienes eligen esta última solución discuten en cuanto a los medios técnicos con los cuales se reducía la condena (diversas conjeturas en EISELE y LEVY). La correspondencia por el residuo solamente (*duplum*) es sin duda la solución preferida por JUSTINIANO.

3. Frente al amplísimo sentido de la palabra *iniuria* en el lenguaje jurídico usual (= *quod non iure fit*), está el significado bastante restringido que se atribuye a la palabra en el sistema de los delitos privados: aquí *iniuria* equivale a lesión personal¹⁵. La ley de las XII Tabas consideraba tres casos: el *membrum ruptum* (amputación de un miembro o inutilización de un órgano), para el cual se conminaba el talión, salvo arreglo voluntario entre ofendido y ofensor; el *os fractum*, que daba lugar a una composición legal, fijada en 300 ases si el ofendido era libre y en 150 si esclavo; las *iniuriae* puras y simples, es decir, las lesiones menores (si *pugno mala percussa sit*, según el ejemplo dado más tarde en la fórmula edictal; *os hominis liberi manus suae palma verberare*, según el necio hábito atribuido por un relato popular al caballero L. Veracio), para las cuales la composición está fijada en 25 ases. En cambio, parece que no cupiese, en el concepto de la *iniuria*, el *malum carmen incantare*, contra el cual se conminaba la pena

¹³ También aquí la persecución privada concurre con la pública, en el sentido de que el autor del robo incurre en las sanciones de las leyes sobre la violencia (*de vi*), y especialmente de la ley Iulia (*de Augusto?* año 17 a. C.?).

¹⁴ Esta aparente anomalía se vincula con el concepto originario del *fur manifestus*, que no es el ladrón "visto robando", sino el "atrapado".

¹⁵ Sobre el tema, PUGLIESE, *Studi sull'iniuria*, I, Milano, 1941.

capital, aunque CÍCERÓN y HORACIO lo interpretasen como composición poética divulgada con el fin de difamación; por el contrario, es probable¹⁶ que la norma se refiriese a fórmulas mágicas pronunciadas para invocar la acción de potencias maléficas contra alguien.

Cada vez más en uso la composición para el *membrum ruptum*, manifestada como demasiado leve y no adaptable a las diversas circunstancias la pena de 25 ases para las lesiones menores, el pretor recogió todos los casos de lesión personal bajo una fórmula, llamada *actio iniuriarum aestimatoria*, con la cual se autorizaba al juez a condenar en los límites del "quantum aequum et bonum sibi videbitur", con la salvedad de que para el caso de *iniuria atrox* el pretor mismo encontraba el modo de imponerle una condena elevada. A esta fórmula siguieron particulares cláusulas edictales que extendieron el concepto de *iniuria* comprendiendo en ella las diferentes especies de *contumelia*: el *convicium*, vociferación pública en ultraje de alguien; la *adtemplata pudicitia*; la *infamatio*, difusión de rumores que se traducen en detrimento de la fama; etc.

La jurisprudencia amplió todavía más el concepto hasta llegar a considerar *iniuria* a toda lesión del derecho de la personalidad; por ejemplo, cualquier impedimento contra la libertad de locomoción o el uso de las cosas *publico usui destinatae*.

La acción se concede (ya hemos visto un caso en las XII Tablas) también por la injuria inferida al esclavo: normalmente corresponde al dueño, salvo el caso de que, estando el esclavo en usufructo o posesión de buena fe de un tercero, la injuria haya tenido el fin de causar daño a quien momentáneamente lo tenía en potestad.

Aquí más que nunca la persecución privada concurre con la pública. La *lex Cornelia de iniuriis* (de L. SILLA) autorizó en algunos casos (*verberatio*, *pulsatio*, violación de domicilio) a la víctima para denunciar al culpable en las formas del proceso penal, a fin de hacerlo juzgar por uno de aquellos jurados que se llamaban *quaestiones perpetuae*, pero siempre para llegar a una pena pecuniaria. En el derecho imperial, entre los *crimina extraordinaria* que se sustituyen al régimen de las *quaestiones perpe-*

¹⁶ HUELIN, *La notion de l'iniuria dans le très ancien droit romain*, en *Mélanges Appleton*, 1903, ps. 367 y ss.; y después de él muchos otros.

tuae, encuentran un lugar cada vez más amplio los casos de injuria; de manera que en el último derecho el ámbito de nuestro delito privado se va restringiendo a las más leves lesiones y contumelias, como así también a las violaciones menores de los derechos de la personalidad.

4. Pero el más interesante, quizá, entre los delitos privados es el que se conoce con el nombre de *damnum iniuria datum*; no sólo y no tanto por la finísima casuística elaborada a su respecto por la jurisprudencia clásica, como por la posición privilegiada concedida a este delito en la época justinianeas y por el ulterior y singularísimo desarrollo histórico que ha preparado la doctrina moderna del delito civil¹⁷.

Los juristas romanos afirman que el delito en examen —al cual mejor que el nombre, para nosotros demasiado comprensivo, de daño, conviene el de acción de dañar— estaba ya previsto por las XII Tablas; pero si la mención es exacta, no tenemos modo de completarla. En cambio, sabemos que una *lex Aquilia* (de fecha incierta, pero indudablemente muy antigua) estableció dos reglas sobre el daño: la primera, que quien hubiese dado muerte a un esclavo o a un animal comprendido en la clase de los *pecudes* quedase obligado a pagar al dueño (*herus* según la denominación arcaica) el más alto precio que hubiese tenido durante el último año; la segunda¹⁸, que el autor de cualquier otro daño (lesión de esclavos o de *pecudes*, muerte o lesión de otros animales, destrucción o deterioro de cosas inanimadas) estuviese obligado a pagar el más alto precio alcanzado por la cosa en el último mes. La obligación estaba expresada por la ley con la frase *damnas esto dare*.

¹⁷ Recuerdo aquí nuevamente los dos escritos de nuestro lamentado ROTONDI, citados en la p. 409, nota 6, y sobre todo la vasta investigación *Dalla lex Aquilia all'articolo 1151, Cod. Civ.*, modelo de indagación histórico-dogmática. Sobre los diversos problemas conservan su valor las investigaciones de FERRINI (*Dir. pen. rom.*, ps. 241 y ss.) y de DE MEDIO (*La legittimazione attiva nell'actio legis Aquiliae*, en *Studi in onore di V. Scialoja*, I, ps. 17 y ss.); véase también CARRELLI, "Riv. Ital. Sc. Giur.", nueva serie, 9, 1934, ps. 356 y ss.

¹⁸ Que es el *caput tertium* de la ley, según el resumen de GAYO, III, 210 y ss. El capítulo segundo contenía la disposición por la cual el *adstipulator* (cap. XVIII, § 1) debía indemnizar al acreedor principal cuando sin su consentimiento hubiera remitido la deuda; la intercalación de esta disposición entre las relativas al daño permanece inexplicada, a pesar de las muchas tentativas al respecto (cfr. KOOIJMAN, *Fragm. iuris. Quiritium*, ps. 140 y ss.).

que autorizaba la ejecución inmediata en las formas de la *manus iniectio*; según los principios de esta *legis actio*, el demandado que negaba el hecho respondía, cuando el delito se probase, no ya *in simplum* sino *in duplum*. De ahí la regla clásica por la cual la acción corresponde *in simplum adversus confitentem*, *in duplum adversus infitiantem* (= *adversus reum qui negat*); sólo en el derecho justiniano se tiende a entender que la *infinitio* exista toda vez que no se pague espontáneamente antes del llamado a juicio y a considerar, en consecuencia, a la acción como correspondiente, sin más, *in duplum*, salvo que se vea en ella —como ya se ha señalado (ps. 410 y ss.)— el resultado de una acumulación de la *rei persecutio* con la *poena*.

El daño previsto por la *lex Aquilia* es solamente el causado *corpore corpori*, es decir, el producido con el esfuerzo muscular del delincuente a la cosa considerada en su estructura física. La sanción de la ley no tiene lugar, en consecuencia, por falta del daño *corpore*, si se encierra el ganado en un establo para hacerlo morir de hambre, o si se persuade a un esclavo de que suba a un árbol, ocasionándole de esa manera la caída y la muerte (GAYO, III, 219). Y menos aún se aplica si se infiere a la cosa un daño no corporal, por ejemplo incitando a un esclavo al vicio o dejándolo huír. Los clásicos encontraban alguna analogía entre los casos en que la ley *Aquilia* era aplicable y algunos otros que quedaban fuera de ella, pero esto solamente si el requisito que faltaba era el del daño causado *corpore*; en tal caso concedían ampliamente, como advierte GAYO, *actiones legis Aquiliae utilis* o acciones *in factum*, de tendencias análogas. Pero frente al requisito de la lesión *corpori*, que expresa la más esencial característica del daño, no admitían analogías; tanto más cuanto que el amplio concepto del hurto, capaz de abrazar cualquier acción sobre la cosa *invito domino*, permitía, muy a menudo, castigar el hecho con una pena equivalente. En el derecho justiniano las cosas cambian; mientras se tiende a hacer coincidir en todo con las acciones normales las acciones útiles o *in factum* concedidas para el daño *non corpore*, la analogía de la ley *Aquilia* es estimulada hasta abrazar los daños *non corpori*; es más: puesto que el concepto del hurto se va restringiendo a los casos de ingerencia en las cosas ajenas con fines de lucro, las hipótesis en las cuales para los clásicos había hurto sin lucro, pasan a ensanchar el campo de aplicación de la

acción de daño. Las diversas acciones *in factum* que los juristas daban caso por caso, forman así la trama sobre la cual los bizantinos ordenan una nueva y mastodóntica *actio in factum*, que es general y se extiende a cualquier hipótesis de daño que no entre en los términos de la antigua ley: *ὑποάκτου γενική ἀγωγή εἰς τὸ ἀζημιον* (*in factum generalis actio ob indemnitatem*) la llaman los maestros bizantinos, y en su sistema ella cumple, respecto del daño extracontractual, la misma función complementaria que en materia contractual desempeña la otra *γενική ἀγωγή*, la *in factum civilis* (o *praescriptis verbis*) nacida de los contratos inno-
minados (ps. 354 y ss.)¹⁹.

En lo referente al elemento subjetivo (bosquejado en el ablativo *iniuria*, aquí en el sentido literal de *quod non iure fit*), parece que la estructura clásica del daño aquiliano se fundara sobre la mera imputabilidad, es decir, sobre el nexo causal entre el hecho del ofensor y el daño. En consecuencia, no sólo desaparece la necesidad de la intención de causar daño (*dolus*), que hemos visto era propia del hurto e igualmente lo es del robo y de la injuria²⁰, sino que también se controvierte el sentido en que se entiende la palabra *culpa*, de la cual a menudo hacen uso a propósito de nuestra acción los juristas, y que más bien, como parece demostrado por el lenguaje gayano, encuentra en esta materia su primera aplicación en la doctrina del daño. Actualmente gana cada vez mayor terreno la opinión²¹ de que la expresión fuera usada por los clásicos en un sentido más amplio, y de cualquier modo diverso, del moderno previsible no previsto, y precisamente en el sentido de un nexo causal entre la actividad voluntaria del individuo y el daño por ella producido. En particular parece decisiva, en este orden de ideas, la existencia de la responsabilidad de los dementes y de los niños, admitida por la jurisprudencia aun a principios del Imperio y sólo fatigosamente excluida (más por razones de oportunidad que de lógica jurídica) por los juristas posteriores, como ULPIANO y PAULO. La ecuación entre culpa y negligencia,

¹⁹ El estudio paralelo de las dos construcciones es el mayor mérito de las investigaciones de DE FRANCISCI sobre el *συνάλλαγμα* (II, ps. 34 y ss.).

²⁰ Se ha sostenido, por lo demás, que en el momento de su implantación, también la ley Aquilia se refiriese a daños causados con dolo.

²¹ Afirmada primero por VENEZIAN, *Danno e risarcim. fuori dei contratti* (en *Opere giuridiche*, I, ps. 77 y ss.); cfr. ROTONDI, *Scr. giur.*, 2, ps. 479 y ss., y KUNKEL, "Rev. Fundac. Savigny", 49, 1929, ps. 157 y ss.